

LGPD EM CASOS

Da teoria à prática

EDSON PIRES DA FONSECA



Aprenda Proteção de Dados resolvendo casos práticos!

Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD  Casos

LGPD em Casos

LGPD em CASOS

da teoria à prática

Licenciado a: dssenna@gmail.com

EDSON PIRES DA FONSECA

Bacharel e Mestre em Direito. MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Especialista em Direito Digital e Compliance pela Faculdade IBMEC/Damásio. Formação em Data Protection Officer pela FGV. Formação em Data Protection Officer pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Coordenador de Curso de Direito. Professor e Consultor em Proteção de Dados. Membro da IAPP - International Association of Privacy Professionals. Membro do Comitê de Ética, Governança e Privacidade da I2AI - International Association of Artificial Intelligence. Autor do Livro Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Editora JusPodivm, 2021).



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD em Casos

EDSON PIRES DA FONSECA

LGPD em CASOS

da teoria à prática

Salvador

Edson Pires da Fonseca

2022

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Edson Pires da Fonseca

Copirraite, 2022, Edson Pires da Fonseca

Todos os direitos reservados.

Proibida a reprodução desta obra, em seu todo ou parte,
e por qualquer processo, sem a permissão do autor.

Digitação e revisão
Edson Pires da Fonseca

Capa
Edson Pires da Fonseca

Diagramação, editoração gráfica
Maria Rodrigues Mendes

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F676l FONSECA, Edson Pires da.

LGPD em casos: da teoria à prática. / Edson Pires
da Fonseca. – Salvador: Edson Pires da Fonseca, 2022.

192 p.
E-book.

Inclui bibliografia.
ISBN: 978-65-00- 28788-2

1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
 2. Proteção de dados. 3. Sistemas de informação gerencial. 4. Direito à privacidade. 5. Poder público - Brasil. I. FONSECA, Edson Pires da. II. Título.
- CDU: 342.721:004(81)

Ficha catalográfica elaborada por Vinícius Silveira de Sousa -
Bibliotecário - CRB6/3073
Licenciado a: dssenna@gmail.com

***“Um passo à frente e você não
está mais no mesmo lugar”***

Chico Science e Nação Zumbi

Edson Pires da Fonseca

Licenciado a: dssenna@gmail.com

À Ericka, Pedro e Rafael, fontes inesgotáveis de amor e inspiração.

À Elvira, Lau, Mauro, Sílvia e Eliana, com gratidão e saudade.

Edson Pires da Fonseca

Licenciado a: dssenna@gmail.com

SUMÁRIO

NOTA DO AUTOR.....	13
INTRODUÇÃO.....	16
1 ESTUDO DE CASO I – Escopo de Aplicação da LGPD	18
1.1 Escopo de Aplicação da LGPD.....	19
1.2 Caso I – A Pousada da D. Elvira.....	22
1.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso I.....	24
2 ESTUDO DE CASO II – Princípios da LGPD.....	29
2.1 Princípios da LGPD.....	30
2.2 Caso II – O Estacionamento da Empresa Belo Monte.....	36
2.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso II.....	38
3 ESTUDO DE CASO III – Bases Legais.....	41
3.1 Bases Legais.....	42
3.2 Caso III – <i>Bufett</i> Sabores.....	51
3.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso III.....	52
4 ESTUDO DE CASO IV – Bases Legais e o RH.....	55
4.1 Bases Legais e o RH.....	56
4.2 Caso IV – A Demissão do Jurandir.....	65
4.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso IV.....	66

5 ESTUDO DE CASO V – Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis.....	68
5.1 Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis.....	69
5.2 Caso V – Aniversariantes do Mês e Religião.....	74
5.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso V.....	75
6 ESTUDO DE CASO VI – Direito dos Titulares – Direito de Revisão de Decisões Automatizadas.....	77
6.1 Direito dos Titulares – Direito de Revisão de Decisões Automatizadas.....	78
6.2 Caso VI – A <i>Fintech</i> e o Cartão de Crédito da Josefa	81
6.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso VI.....	82
7 ESTUDO DE CASO VII – Agentes de Tratamento e a Responsabilidade por Incidentes.....	84
7.1 Agentes de Tratamento e a Responsabilidade por Incidentes.....	85
7.2 Caso VII – A Folha de Pagamento da Porto Golden.....	89
7.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso VII.....	91
8 ESTUDO DE CASO VIII – Poder Público e os Agentes de Tratamento à Luz do Guia Orientativo da ANPD..	96
8.1 Poder Público e os Agentes de Tratamento à Luz do Guia Orientativo da ANPD.....	97
8.2 Caso VIII – O Tribunal como Controlador de Dados.....	100
8.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso VIII...	101

Licenciado a: dssenna@gmail.com

9 ESTUDO DE CASO IX – Sanções Administrativas na LGPD.....	103
9.1 Sanções Administrativas na LGPD.....	104
9.2 Caso IX – O Vazamento de Dados da Mix Telecom.....	110
9.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso IX.....	112
10 ESTUDO DE CASO X – A Comunicação de Incidentes à ANPD e aos Titulares.....	115
10.1 A Comunicação de Incidentes à ANPD e aos Titulares.....	116
10.2 Caso X – O Incidente de Segurança do Banco Verde.....	124
10.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso X.....	126
11 ESTUDO DE CASO XI – Tratamento de Dados Pelo Poder Público.....	128
11.1 Tratamento de Dados pelo Poder Público.....	129
11.2 Caso XI – Empresa Pública e Violação à LGPD.....	136
11.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso XI.....	137
12 ESTUDO DE CASO XII – Tratamento de Dados de Criança e Adolescente.....	139
12.1 Tratamento de Dados de Criança e Adolescente.....	140
12.2 Caso XII – A Escola Infantil XYZ e o Uso de Imagens dos Estudantes.....	147
12.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso XII	149

13 ESTUDO DE CASO XIII	– Hipóteses de Não In-
cidência da LGPD.....	152
13.1 Hipóteses de Não Incidência da LGPD.....	153
13.2 Caso XIII – A LGPD e a Emissora de Tele-	
visão XYZ.....	157
13.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso XIII	159
14 ESTUDO DE CASO XIV	– Legítimo Interesse do
Controlador.....	162
14.1 Legítimo Interesse do Controlador.....	163
14.2 Caso XIV – Sorria, Você Está Sendo Filmado	170
14.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso XIV	172
15 ESTUDO DE CASO XV	– Responsabilidade e
Ressarcimento.....	173
15.1 Responsabilidade e Ressarcimento.....	176
15.2 Caso XV – O Concerto do Notebook da Clí-	
nica Beta.....	184
15.3 Da Teoria à Prática: Resolução do Caso XV..	186
REFERÊNCIAS	189

NOTA DO AUTOR

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, é uma das leis brasileiras mais impactantes das últimas décadas. Com a importância crescente dos dados pessoais para a economia, evidencia-se, ao redor do mundo, a necessidade de aprovação de legislações de proteção de dados pessoais que protejam o titular dos dados de investidas que violem seu direito fundamental à privacidade e à proteção dos dados pessoais, ao mesmo tempo que proporcionam segurança jurídica para a inovação e o desenvolvimento tecnológico.

A vigência da LGPD demanda a **formação de dezenas de milhares de profissionais**, oriundos de diferentes áreas do conhecimento, indispensáveis às mais diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Com o intuito de contribuir para o fortalecimento do ecossistema de privacidade e proteção de dados pessoais, apresentamos este livro, **LGPD em CASOS**, fruto de mais de uma década e meia de experiência docente, especialmente com **metodologias ativas de aprendizagem**, que colocam o *aprendente* no centro do processo educacional, como seu **protagonista**. **Teoria e prática** entrelaçam-se para a **resolução de casos**, possibilitando o desenvolvimento

Licenciado a: dssenna@gmail.com

dos principais conceitos, institutos e bases teóricas da LGPD em diferentes contextos de aplicação, o que torna o aprendizado mais efetivo e significativo.

Escrito em **linguagem didática e objetiva**, pode ser compreendido por estudantes e profissionais de **diferentes áreas do conhecimento**, o que é fundamental em uma seara como a proteção de dados, que exige **conhecimentos jurídicos, de TI, segurança da informação, gestão etc.**

Metodologia. O livro é composto por **quinze estudos de casos**, que abordam alguns dos principais aspectos da LGPD. Cada estudo de caso está dividido em três partes. Inicialmente há uma **breve introdução ao tema objeto do estudo**, possibilitando ao leitor conhecer o estado da arte daquele assunto. Em seguida, **apresenta-se o caso**, com instruções para a sua resolução. Por fim, será apresentada **uma proposta de resolução do caso**, com as explicações teóricas e legislativas que justificam a hipótese de solução adotada.

O livro será **útil** tanto para quem **está iniciando os estudos** quanto para quem está em **busca de aprofundamento**. Para quem está iniciando os estudos, aprenderá a partir de algumas possibilidades de aplicação da teoria; para quem já iniciou os estudos, treinar resolvendo casos contribuirá para a solidificação e diversificação do aprendizado, tornando-o mais robusto e efetivo, o que é essencial para a atuação profissional em

privacidade e proteção de dados pessoais.

Em síntese, a **proposta** do livro **LGPD em CASOS** é contribuir para o aprendizado em proteção de dados, resolvendo problemas que abordam o tema estudado, tornando mais efetivo o aprendizado, pois **a teoria será aprendida na prática**, em diferentes contextos de aplicação.

Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este fascinante, instigante e promissor ecossistema de privacidade e proteção de dados.

Bons estudos!

Edson

16 de dezembro de 2021

INTRODUÇÃO

O objetivo desta obra é proporcionar aprendizado acerca de alguns dos principais tópicos da LGPD, a partir da resolução de casos que abordam diferentes aspectos da Lei. Não se trata, portanto, de obra doutrinária voltada à discussão minuciosa da lei e nem tampouco de todos os seus dispositivos. Para isso, indicamos outras obras nas referências bibliográficas, inclusive a nossa, intitulada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais¹.

O livro está dividido em **quinze estudos de casos**. Cada estudo de caso será precedido de sucinta abordagem teórica e legislativa, que permitirá conhecer ou relembrar os principais aspectos da Lei relacionados à matéria em estudo. Esse estudo prévio ajudará a melhorar a compreensão do problema que será proposto. Na sequência, será apresentado o **estudo de caso**, que terá como objetivo verificar uma ou mais hipóteses de aplicação daquele conceito que está sendo estudado. Nesse momento, para **potencializar o seu aprendizado**, recomenda-se que antes de ler a proposta de resolução

¹ FONSECA, Edson Pires. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**. Salvador: Editora Juspodivm, 2021.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

apresentada para o estudo de caso você tente resolvê-lo, elencando os pontos que considera centrais, as hipóteses de resolução e a resolução.

Por fim, será apresentada uma **proposta de resolução do caso**, com os fundamentos utilizados para a construção da resposta, contribuindo para melhor compreensão do caso, para a consolidação da aprendizagem, visualizando como alguns institutos da LGPD são aplicados na construção de respostas a problemas práticos.

O estudo da teoria por meio da resolução de casos potencializará o seu aprendizado, tornando-o mais **significativo** e conectado aos contextos de aplicação que encontrará na **atuação profissional**. Como dito na apresentação, não integra a proposta desta obra esgotar todos os pontos da LGPD, mas proporcionar o contato com alguns dos seus principais institutos, aliando teoria e prática, ao mesmo tempo que contribui para desenvolver as competências e habilidades necessárias para a resolução de problemas concretos.

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO I

ESCOPO DE APLICAÇÃO DA LGPD



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

1.1 ESCOPO DE APLICAÇÃO DA LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aplica-se a todo tratamento de dados pessoais realizado por **pessoa natural**, que exerce atividade econômica, ou por **pessoa jurídica**, seja ela de direito privado ou público. Os dados pessoais² podem estar em meio físico (papel, por **exemplo**) ou digital. Os bancos de dados existentes antes da entrada em vigor da LGPD, que ocorreu em **18 de setembro de 2020**, também devem ser adequados à Lei.

A LGPD é uma **lei principiológica**, repleta de **conceitos indeterminados**, o que proporciona maior abertura aos seus intérpretes, ao mesmo tempo que amplia o ônus argumentativo na sua aplicação.

Os **artigos iniciais da LGPD** trazem os seus **fundamentos** (art. 2º), **esfera de incidência** (art. 3º), hipóteses em que a **Lei não se aplica** (art. 4º), **conceitos e definições** (art. 5º), **princípios** (art. 6º), **bases legais** que autorizam o tratamento de dados (art. 7º) e tratamento de **dados pessoais sensíveis** (art. 11).

² Dados pessoais é tudo aquilo que identifica ou pode identificar uma pessoa natural (art. 5, I, LGPD).

A Lei deve ser interpretada à luz desses fundamentos, conceitos e princípios, de maneira sistemática, evitando-se uma leitura meramente literal de um artigo isolado. Compreender os conceitos, fundamentos, princípios e as hipóteses autorizativas do tratamento de dados pessoais é essencial para a correta aplicação da Lei.

Destaca-se que a LGPD pode ser aplicada a organizações sediadas fora do Brasil, desde que ofereçam produtos ou serviços a quem está em território brasileiro, seja estrangeiro ou brasileiro³.

No artigo 4º, a LGPD⁴ consagra algumas situações

³ Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, **independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados**, desde que: I - a operação de tratamento seja **realizada no território nacional**; II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a **oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional**; ou III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. § 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. § 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei (sem grifos no original).

⁴ Art. 4º **Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais**: I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei (sem grifos no original).

nas quais ela não se aplica, destacando-se o tratamento de dados realizado para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, bem como o tratamento realizado por pessoa natural, para finalidade particular e não econômica. A LGPD não se aplica a **fins exclusivos de segurança pública**, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais e os que são oriundos do exterior “e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei”.

Feita esta introdução, apresentaremos o primeiro caso, que explorará esta parte inicial da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, clareando situações nas quais a LGPD será aplicada.

1.2 CASO I – A POUSADA DA D. ELVIRA

Elvira é proprietária da Pousada Lua, uma das mais destacadas do litoral norte da Bahia. A Pousada está anunciada no *Booking*, *Hotel Urbano*, *Submarino Viagens*, *Trip Advisor*, entre outros. Elvira costuma impulsionar postagens sobre a Pousada Lua em publicações veiculadas em Portugal e na Espanha, o que atrai inúmeros hóspedes residentes nestes países. Douglas é proprietário da Pousada Recantos da Bahia, vizinha à de Elvira. Diferente de Dona Elvira, a divulgação da Recantos da Bahia é feita exclusivamente no “boca a boca”. O seu foco são os frequentadores da região. Não há divulgação formal, muito menos no exterior. Douglas se orgulha de ter uma pousada criada para atender os moradores da região, pessoas que ele conhece como ninguém. De vez em quando, no entanto, a Pousada Recantos da Bahia hospeda turistas europeus atraídos pela divulgação feita por Elvira na Europa, que chegam sem reserva e não encontram vagas na Pousada Lua. Em alguns finais de semana, a Pousada de Douglas ficou lotada de turistas europeus, especialmente de Portugal, que gostam da simplicidade do lugar.

Com a entrada em vigor da LGPD, a Secretaria Estadual de Turismo realizou um seminário direcionado aos proprietários e colaboradores de estabelecimentos que recebem turistas que frequentam o litoral. Elvira

Licenciado a: dssenna@gmail.com

e Douglas participaram do evento, no qual foram informados da necessidade de adequação à LGPD. Quem recebe turista europeu também deve se adequar ao GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Assim, os que recebem turistas europeus e brasileiros devem se adequar a ambas as legislações.

Uma entidade representativa do setor de turismo da Argentina, que estava estreitando os laços com a Secretaria de Turismo, também participou do Seminário. De acordo com a entidade, muitos hotéis argentinos divulgam os seus serviços para o público brasileiro: patrocinam anúncios em sites do Brasil, traduzem seus sites para o português e aceitam pagamentos em reais. O representante argentino questionou o palestrante se as empresas argentinas teriam de se adequar à LGPD. A resposta foi que não seria necessário, pois não estão situadas e nem prestam serviços no Brasil.

Depois do Seminário, Elvira e Douglas procuraram o seu escritório, especializado em proteção de dados pessoais, para que os orientasse sobre as informações que receberam.

Instruções: analise o caso apresentado à luz da LGPD e destaque quais são os seus aspectos centrais; verifique a necessidade de adequação das pousadas de Elvira e Douglas à LGPD e ao GDPR, bem como as informações repassadas durante o seminário aos brasileiros e argentinos.

1.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO I

A resolução deste caso passa pela análise do **artigo 3º da LGPD**. Envolve, ainda, o GDPR, em situação de aplicação semelhante à prevista pela LGPD. O caso exige conhecimento de alguns contextos de aplicação da LGPD e do GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia), inclusive para empresas não sediadas no Brasil.

Em síntese, o caso aborda a divulgação realizada pelas pousadas de Dona Elvira e do Senhor Douglas, cada uma com a sua estratégia e segmentação de clientes. Enquanto a pousada de Elvira busca atrair turistas europeus, Douglas restringe a divulgação ao “boca a boca”, com foco exclusivo em pessoas da região, embora esporadicamente receba turistas europeus que chegam espontaneamente à pousada. Diante disso, o **questionamento central** trata da necessidade de adequação das pousadas à LGPD e ao GDPR, considerando todas as informações trazidas no caso, inclusive as que foram passadas durante o seminário. Também é necessário analisar a indagação feita pelo representante argentino acerca da aplicabilidade da LGPD às empresas sediadas na Argentina e que oferecem serviços a brasileiros que estão no Brasil.

Para tornar mais didática a análise, primeiramente analisaremos a necessidade de adequação da Pousada

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Lua, da Senhora Elvira, às mencionadas legislações de proteção de dados pessoais.

a) POUSADA LUA (DONA ELVIRA):

Necessidade de adequação ao GDPR? a Pousada de Dona Elvira oferece os seus serviços a pessoas residentes na União Europeia, **que estão na Europa no momento da oferta**. Diante disso, deve se adequar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (art. 3º)⁵. Não é pelo fato de receber turistas europeus que Dona Elvira necessita adequar a Pousada Lua ao GDPR, mas por **oferecer os seus serviços a pessoas residentes na União Europeia** (Portugal e Espanha), **que estão na Europa no momento da oferta**. Se ela oferecesse o serviço a pessoas residentes na União Europeia, mas que

⁵ **Artigo 3.º Âmbito de aplicação territorial** 1. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante situado no território da União, independentemente de o tratamento ocorrer dentro ou fora da União. 2. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União, efetuado por um responsável pelo tratamento ou subcontratante não estabelecido na União, quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com:

- a) A oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procederem a um pagamento;
 - b) O controlo do seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União.
3. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais por um responsável pelo tratamento estabelecido não na União, mas num lugar em que se aplique o direito de um Estado-Membro por força do direito internacional público.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

estivessem no Brasil no momento da oferta, não haveria necessidade de adequação ao GDPR, apenas à LGPD. Mas não é isso o que ocorre.

Na análise do caso, fica evidente que a Pousada Lua **oferece** serviços a pessoas que residem e estão na União Europeia no momento da oferta. O caso relata que a Pousada Lua oferece os seus serviços em plataformas internacionais como a Booking, além de **impulsionar anúncios em publicações portuguesas e espanholas**, evidenciando o direcionamento de serviços a pessoas localizadas na União Europeia. Se Dona Elvira recebesse turistas residentes em Portugal e Espanha que estão explorando pontos turísticos no Brasil e conheceram a Pousada Lua em uma postagem destinada a brasileiros residentes no Brasil, não haveria necessidade de adequação ao GDPR.

Necessidade de adequação à LGPD? A Pousada Lua, de propriedade de Dona Elvira, está localizada no litoral baiano. É pessoa jurídica de direito privado, que trata dados pessoais, portanto deve se adequar à LGPD (art. 1º). Lembra-se que a LGPD se aplica às **pessoas naturais** que tratam dados com **finalidade econômica** e às pessoas jurídicas de direito privado e público, que tratam dados em meio físico ou digital.

b) POUSADA SENHOR DOUGLAS

Desnecessidade de Adequação ao GDPR. Embora eventualmente receba turistas da União Europeia,

Licenciado a: dssenna@gmail.com

atraídos pela publicidade feita em Portugal e Espanha pela Pousada Lua, de Dona Elvira, a Pousada do Senhor Douglas **não precisa se adequar ao GDPR**, pois não oferece seus serviços a pessoas residentes na União Europeia e que estejam na União no momento da oferta.

Necessidade de Adequação à LGPD. Como pessoa jurídica de direito privado, localizada no Brasil, que trata dados pessoais, a Pousada do Senhor Douglas deve se adequar à LGPD.

c) HOTÉIS ARGENTINOS QUE OFERECEM SERVIÇOS A BRASILEIROS QUE ESTÃO NO BRASIL

Os hotéis argentinos que oferecem os seus serviços a brasileiros que estão no Brasil, o que é evidenciado pela tradução do site para o português, patrocínio a sites brasileiros, recebimento do pagamento em real, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, conforme disposto no **artigo 3º, inciso II**⁶,

⁶ Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que: I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. § 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. § 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.

que estabelece que a LGPD se aplica quando “II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional”. No caso dos hotéis argentinos, a oferta do serviço tem por objeto indivíduos localizados no Brasil. Nota-se que o destinatário do serviço não precisa ser brasileiro ou residente, apenas que esteja no território nacional durante a oferta.

DIRETO AO PONTO: Ambas as pousadas precisam se adequar à LGPD, mas apenas a Pousada Lua, de D. Elvira, precisa se adequar ao GDPR, pois somente ela oferece o seu serviço para indivíduos residentes na União Europeia e que estão na União no momento da oferta. Os hotéis argentinos precisam se adequar à LGPD, já que oferecem os seus serviços a indivíduos que estão no Brasil no momento da oferta.

ESTUDO DE CASO II

PRINCÍPIOS DA LGPD



Licenciado a: dssenna@gmail.com

2.1 PRINCÍPIOS DA LGPD

A LGPD é uma lei principiológica e permeada de conceitos indeterminados. Ambas as espécies de normas são escritas em linguagem aberta, proporcionando maior amplitude interpretativa.

Mas qual é a importância disso? Como a LGPD trata de temática conectada ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, normas com linguagem mais aberta absorvem melhor as constantes transformações sociais e as inovações. Os princípios trazem o DNA, as características mais relevantes da LGPD, razão pela qual muitas normas da LGPD são concretizações dos princípios⁷.

Os fundamentos e princípios de uma lei revelam o seu DNA, a sua essência, e devem servir de parâmetro para a interpretação da Lei. Em outras palavras, toda a interpretação da LGPD deve considerar os seus fundamentos e princípios.

⁷ Caso queira saber mais sobre a normatividade dos princípios, conferir: DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2010; ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017; FONSECA, Edson Pires. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**. Salvador: Editora Juspodivm, 2021.

Os fundamentos da LGPD estão previstos no artigo 2º, enquanto os princípios estão disciplinados no artigo 6º. São **fundamentos da LGPD** (art. 2º):

- I - o respeito à privacidade;
- II - a autodeterminação informativa;
- III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
- V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
- VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
- VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Toda a LGPD e a sua aplicação devem respeitar e homenagear esses fundamentos. Os direitos dos titulares e as obrigações impostas aos agentes de tratamento, por exemplo, são formas de concretizar os fundamentos e os princípios da Lei. Na resolução de problemas de proteção de dados, seja o juiz, julgando um caso que envolva proteção de dados, seja um consultor, indicando uma solução a um cliente durante a implementação de um programa de conformidade com a LGPD, devem considerar os fundamentos e os princípios da Lei Geral de Proteção

Licenciado a: dssenna@gmail.com

de Dados Pessoais como balizas da interpretação que farão da Lei.

Os princípios estão localizados no **artigo 6º** da LGPD e juntamente com os fundamentos constituem a **essência**, o DNA, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. De acordo com o artigo 6º da LGPD, as atividades de tratamento de dados devem observar a **boa-fé** e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis

Licenciado a: dssenna@gmail.com

sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Os princípios da LGPD constituem importantes balizas para a estruturação de um ambiente de proteção dos dados pessoais, manifestações da personalidade humana, ao menos tempo que apontam os cuidados que as organizações devem tomar no tratamento de dados, fomentando o desenvolvimento econômico e tecnológico.

Cada inciso acima transcrito apresenta um princípio da LGPD e a explicação do seu conteúdo. Fica claro que não é mais possível o tratamento de dados sem uma finalidade específica. Além disso, deve-se tratar apenas os dados necessários à finalidade declarada.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Em outras palavras, o tratamento de dados pressupõe uma finalidade específica e os dados tratados devem ser apenas os que são necessários para que se atinja esta finalidade. Há entre muitas organizações a chamada “fome de dados”, que consiste em coletar o máximo de dados possível, sob a alegação que podem ser úteis no futuro. A LGPD põe fim a essa prática, restringindo o tratamento de dados aos que são necessários à finalidade que justificou o tratamento. A coleta excessiva de dados, além de ampliar os custos com o armazenamento e a proteção desses dados, aumenta os riscos da organização e **viola a LGPD**.

Como a LGPD tem como um dos seus fundamentos a autodeterminação informativa, isso ajuda a compreender o **princípio do livre acesso**, segundo o qual o titular dos dados pessoais tem a garantia de consulta facilitada sobre todas as etapas do tratamento, bem como o acesso à integralidade dos seus dados. O **princípio da qualidade dos dados** garante ao titular o direito de que os dados em tratamento sejam atuais e corretos, refletindo o seu momento atual. O tratamento de dados desatualizados pode ocasionar prejuízos ao titular, como, por exemplo, considerar em uma análise de crédito uma negativação que não existe mais.

O **princípio da transparência** norteia as relações entre os agentes de tratamento e os titulares dos dados, que devem ser claramente informados sobre os diferentes aspectos do tratamento, pois possuem **autodeterminação**

Licenciado a: dssenna@gmail.com

informativa, tendo o direito de ser informados sobre o tratamento, inclusive quando a base legal que o autorizou não for o consentimento.

2.2 CASO II – O ESTACIONAMENTO DA EMPRESA BELO MONTE

A Empresa Belo Monte trabalha na área de produção de móveis. Como fica afastada da cidade, oferece transporte aos seus funcionários, que passa pela região central da cidade uma hora e meia antes do início da jornada de trabalho. Para quem prefere ir com veículo próprio, o que tem sido mais frequente nesses tempos de pandemia, a empresa oferece estacionamento próprio, operacionalizado pela Belo Monte. Para acessar o estacionamento, o RH solicitou que os funcionários da Belo Monte apresentem cópias dos seus documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, número de telefone celular, telefone residencial e do ramal da empresa, CNH e cópia do licenciamento do veículo. Se o veículo não estiver em nome do próprio funcionário, deverá apresentar a documentação do proprietário, bem como um termo de autorização para uso do veículo. De acordo com o RH, essas medidas são necessárias para garantir a segurança de todos, evitando que veículos em desconformidade com as leis brasileiras sejam estacionados nas dependências da empresa. O estacionamento é gerenciado pela própria Belo Monte, atendendo exclusivamente os seus funcionários, clientes e visitantes. Para clientes e visitantes, além do RG, CPF e CNH, também é exigido o licenciamento, que é copiado e armazenado.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Instruções: como consultor responsável pelo programa de adequação da Belo Monte à LGPD, analise o tratamento de dados pessoais realizado pelo RH para que os colaboradores possam utilizar o estacionamento da empresa.

2.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO II

Na explicação prévia sobre a matéria foram feitas algumas considerações sobre os princípios e o papel que ocupam no sistema normativo, das quais resgataremos as mais relevantes para a resolução do caso⁸.

Os princípios são normas que contribuem para a estruturação de um sistema normativo, expressando a sua identidade mais profunda. Por esse motivo é que toda a LGPD deve ser lida à luz dos seus fundamentos e princípios. Na **implementação da LGPD** em uma organização, **os fundamentos e princípios** guiarão a atividade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Os princípios da LGPD estão previstos no **artigo 6º**, começando pela finalidade, adequação e necessidade. Todo tratamento de dados deve obedecer a uma finalidade específica e se restringir aos dados estritamente necessários para se atingir a finalidade declarada, em

⁸ Como visto, os princípios são muito importantes em legislações como a LGPD, pois uma área como a proteção de dados pessoais, fortemente relacionada à tecnologia e à inovação, está sujeita a frequentes modificações, razão pela qual se a Lei tratar tudo de forma minuciosa desatualizará rapidamente. Dessa maneira, normas com linguagem mais aberta, como os princípios, assimilam melhor as modificações sociais, sem a necessidade de atualização frequente da Lei. Por outro lado, normas mais abertas exigem maior atividade regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pois diversas questões importantes para a eficácia integral da LGPD ficam dependentes de normatizações da ANPD.

harmonia com o princípio da adequação, que estabelece a “compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento”.

Na análise do caso, fica nítida a **violação ao princípio da necessidade**. Os dados coletados deveriam se **restringir ao mínimo necessário** para se atingir a finalidade declarada, que é possibilitar o acesso seguro ao estacionamento da empresa. Nota-se, porém, a **“fome de dados”** da Belo Monte, que solicita dados desnecessários à finalidade, como comprovante de residência, telefone residencial, cópia da CNH e do licenciamento do veículo. Nota-se facilmente que muitos desses dados são desnecessários à finalidade do tratamento.

A segurança que o estacionamento precisa proporcionar aos seus usuários e à organização não se confunde com o papel que deve ser desempenhado pelas autoridades de segurança pública. O princípio da necessidade estabelece que os dados tratados devem ser os mínimos necessários para que se atinja a finalidade que justificou o tratamento. Dessa maneira, não há justificativa para o estacionamento exigir o licenciamento dos veículos, o que além de violar o princípio da necessidade, faz com que a empresa se comprometa a armazenar dados excessivos, atraindo risco desnecessário para a operação. Com a cópia do licenciamento, por exemplo, é possível acessar dados mais restritos sobre o veículo.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Outro exemplo: será necessário coletar o telefone residencial de quem acessou o estacionamento, se quando o carro está estacionado a pessoa não estará em casa? Isso sem falar que como a imensa maioria de usuários é de funcionários e clientes, a empresa, em caso de necessidade, disporia de outros meios para localizar essas pessoas, como as próprias identificações funcionais, que não tem relação com a vida externa do colaborador.

Além de trazer um risco desnecessário à organização, que se obriga a proteger dados absolutamente desnecessários, a prática adotada no estacionamento da Belo Monte viola a LGPD, sujeitando a organização às sanções previstas no artigo 52 da Lei. A cultura de muitas organizações era a de coletar o máximo de dados possíveis, pois poderiam ser úteis no futuro. Com a entrada em vigor da LGPD, deve-se coletar apenas os dados estritamente necessários para se atingir a finalidade declarada. É isso o que está expressamente previsto no artigo 6º, inciso III, da LGPD: “necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados”.

Dessa maneira, **como responsável pela implementação do programa de conformidade da Belo Monte à LGPD**, Você deve orientar o RH a restringir os dados coletados no estacionamento ao mínimo necessário para se atingir a finalidade do tratamento, que é permitir que funcionários, clientes e visitantes estacionem os seus veículos em segurança.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

ESTUDO DE CASO III

BASES LEGAIS



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

3.1 BASES LEGAIS

O tratamento de dados pessoais pode ser realizado **somente** nas dez hipóteses autorizadas pelo **artigo 7º** da LGPD. Tratando-se de **dados sensíveis**, as hipóteses autorizativas são mais restritas e estão previstas **no artigo 11**, como se verá adiante. As hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais também são conhecidas como **bases legais**.

Conhecer as bases legais, isto é, as hipóteses nas quais a Lei autoriza o tratamento de dados pessoais, é fundamental para a estruturação do programa de adequação de uma organização à LGPD. Escolher a base legal aplicável a cada conjunto de dados em tratamento é uma **obrigação** do **controlador** essencial para a conformidade com a Lei. Se não for possível enquadrar o tratamento em uma das bases legais previstas no artigo 7º, o tratamento de dados será **ilegal** e deve ser imediatamente interrompido ou não iniciado.

A primeira e mais conhecida base legal é o **Consentimento**. Como o titular dos dados possui **autodeterminação informativa** (art. 2º, II), o consentimento é uma forma de demonstrar a sua concordância com o tratamento dos seus dados.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Embora seja a mais conhecida base legal, nem sempre o consentimento será a hipótese mais indicada para o caso concreto. Em primeiro lugar, porque o **ônus** de demonstrar que o consentimento foi obtido nos termos da Lei é do **controlador**; outro ponto em desfavor do consentimento é que em algumas relações, como a trabalhista, fica difícil demonstrar que o consentimento foi livre.

Por fim, a mesma facilidade que o titular teve para consentir ele deve ter para revogar o consentimento, o que, em determinadas situações, pode fragilizar o controlador. No caso de um incidente, por exemplo, os titulares podem revogar em massa o consentimento, colocando a continuidade do negócio em risco. Oportuno destacar que o consentimento não é superior às outras nove base legais previstas no artigo 7º da LGPD.

Outra base legal que será muito demandada é o **LEGÍTIMO INTERESSE do controlador**. Contraponto ao consentimento, permite que o tratamento de dados seja realizado quando houver um interesse legítimo do controlador, exceto quando prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular.

Embora proporcione grande abertura para as hipóteses legais de tratamento de dados, deixando o controlador menos dependente do consentimento, traz consigo **elevado risco jurídico**, o que justifica que a sua utilização seja, em regra, precedida de uma **Avaliação**

de Legítimo Interesse. Somente se o tratamento de dados almejado passar pelas três etapas da Avaliação de Legítimo Interesse, ou LIA⁹, como denominada na União Europeia, é que o legítimo interesse poderá ser utilizado como base legal¹⁰.

Existe controvérsia sobre a necessidade de elaboração de **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, RIPD**, sempre que se utilizar legítimo interesse como base legal. Embora a elaboração do RIPD seja recomendável sempre que possível, pois homenageia princípios como o da **boa-fé, prevenção e segurança**, o RIPD deve ser obrigatoriamente elaborado quando o tratamento de dados com base no legítimo interesse trazer consigo **riscos às liberdades civis e aos direitos dos titulares** (art. 5º, XVII da LGPD)¹¹. Não nos parece razoável a elaboração do RIPD em todas as ocasiões em que a base legal for o legítimo interesse, se não houver risco às liberdades civis e aos direitos dos titulares.

⁹ *Legitimate Interests Assessment – LIA*.

¹⁰ Em outro tema abordado nesta obra, o legítimo interesse será trabalhado em mais detalhes. Ressalva-se que **não há consenso doutrinário** sobre a necessidade de formalização do LIA em toda operação que utiliza o legítimo interesse. De qualquer modo, mesmo nos casos de baixa complexidade, em que a utilização do legítimo interesse se justifique mais facilmente, gera mais segurança registrar o processo decisório, ainda que em procedimento mais simplificado do que o realizado em situações mais complexas.

¹¹ Art. 5º [...] XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

A elaboração do RIPD deve estar atrelada ao **risco** que a operação de tratamento proporciona e não à base legal utilizada. A **ANPD** está tomando subsídios sobre o tema, dialogando com especialistas de variados setores, e, em breve, deve apresentar orientações detalhadas sobre as hipóteses nas quais será obrigatória a elaboração do RIPD, bem como o formato que ele deve ter.

Outra base bastante utilizada é a **EXECUÇÃO DE CONTRATO** ou de **procedimentos preliminares** relacionados a contrato do qual o titular seja parte, sempre mediante a sua própria solicitação (art. 7º, inciso V)¹². Essa base legal somente poderá ser utilizada quando o tratamento de dados pessoais, de fato, for necessário para a execução do contrato. Não basta que algo esteja previsto no contrato para justificar a utilização desta base legal, será necessário que para o agente de tratamento executar o contrato ele necessite tratar os referidos dados. Para que um contrato de compra de um produto em um comércio eletrônico seja executado, por exemplo, será necessário o tratamento dos dados do comprador para que a entrega seja realizada. A execução de contrato não autoriza o tratamento de dados sensíveis, por falta de previsão no artigo 11, inciso II, da LGPD.

ÓRGÃO DE PESQUISA pode tratar dados para a realização de estudos, mas sempre que possível deve

¹² Art. 7º, V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

garantir a anonimização dos dados. O órgão de pesquisa precisa ser vinculado à Administração Pública direta ou indireta. Se for vinculado a pessoa jurídica de direito privado, somente poderá se valer dessa base legal se a pessoa jurídica não tiver fim lucrativo.

A LGPD considera órgão de pesquisa: “órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico” (art. 5º, XVIII). **Exemplos** de órgãos de pesquisa que podem se valer dessa base legal são a Fiocruz, Instituto Butantã, universidades públicas, entre outros. Órgão de pesquisa vinculado a universidade privada somente poderá se valer dessa base legal se a instituição não tiver fim lucrativo.

A LGPD estabelece que o tratamento de dados realizado pelos órgãos de pesquisa para fins de estudos deve ser precedido, **sempre que possível**, da **anonimização** dos dados. Nosso entendimento, salvo melhor juízo, é de que se sempre que possível os dados devem ser anonimizados, a regra será a anonimização. Quando ela não for possível, o controlador deve justificar o motivo pelo qual, naquela situação específica, a anonimização não pôde ser realizada.

O **EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS** autoriza o tratamento de dados pessoais, seja em processo judicial, administrativo ou arbitral. Não fosse assim, o controlador não poderia exercer direitos constitucionalmente garantidos, como o acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Um fornecedor pode, por **exemplo**, se recusar a atender o requerimento de um consumidor para que elimine seus dados se comprovar que eles são necessários ao regular exercício dos seus direitos em um processo judicial.

A **PROTEÇÃO DA VIDA OU DA INCOLUMIDADE FÍSICA** do titular ou de terceiro também autoriza o tratamento de dados sem o consentimento do titular. Essa base legal deve ser utilizada em situações excepcionais, como a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, na qual a utilização de geolocalização de celulares auxiliou nas buscas¹³. Outros **exemplos**: a localização de pessoas desaparecidas ou vítimas de sequestro são situações nas quais o tratamento de dados de geolocalização pode ser útil para a proteção da vida ou da incolumidade física.

O artigo 7º, inciso VIII, da LGPD, autoriza o tratamento de dados pessoais para a **TUTELA DA SAÚDE**, em procedimento realizado exclusivamente por profissionais

¹³ O rompimento da barragem de Brumadinho ocorreu em 25 de janeiro de 2019, ocasião em que a LGPD, embora já promulgada desde 14 de agosto de 2018, ainda não estava em vigor, o que ocorreu em 18 de setembro de 2020.

da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Embora os dados de saúde sejam classificados como sensíveis, nem sempre a tutela da saúde exigirá o tratamento de dados sensíveis. Se os dados necessários para a tutela da saúde forem sensíveis, incidirá o artigo 11, inciso II, alínea “f”, da LGPD.

Por último, a LGPD autoriza o tratamento de dados para a **PROTEÇÃO AO CRÉDITO**. Essa base legal não autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis, por falta de previsão no artigo 11.

Destaca-se, por fim, que o objetivo desta abordagem não é esgotar o tema, mas apresentar alguns subsídios necessários para a resolução do caso concreto que será proposto na sequência, seguindo a metodologia adotada nesta obra. A base legal que autoriza o tratamento de dados pela Administração Pública será abordada em separado, em outro estudo de caso.

O correto enquadramento de uma operação de tratamento de dados pessoais a uma base legal é essencial para a adequação à LGPD. Trata-se, como visto, de obrigação do controlador que, se não cumprida a contento, coloca a operação em desconformidade com a LGPD, com a consequente aplicação de sanção. Na União Europeia, sob a vigência do GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados), uma das principais causas de aplicação de sanções é o incorreto enquadramento da operação de tratamento à base legal. Recomendamos o

Licenciado a: dssenna@gmail.com

estudo atento dos dez incisos do artigo 7º da LGPD, bem

¹⁴ Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; X - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. § 1º (Revogado). § 2º (Revogado). § 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. § 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei. § 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei. § 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. § 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

como de obras que auxiliem no aprofundamento do tema.

Lembre-se que o tratamento de **dados pessoais sensíveis** tem outro rol de bases legais autorizativas, descritas no **artigo 11** da LGPD. Três das bases legais acima descritas, a **execução do contrato**, o **legítimo interesse e à proteção ao crédito**, não podem ser utilizadas para o tratamento de dados pessoais sensíveis, por ausência de previsão legal¹⁵.

¹⁵ Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu responsável legal **consentir**, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; II - **sem fornecimento de consentimento do titular**, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais (sem grifos no original).

3.2 CASO III – **BUFFET SABORES**

O **Buffet Sabores**, especializado em festas e eventos, interessado em estreitar os laços com os seus clientes, incluiu nos contratos que celebra uma cláusula na qual estabelece que pode enviar divulgações de seus produtos e serviços para o e-mail ou *WhatsApp* do cliente. Sueli, cliente do Buffet, ficou aborrecida com a quantidade de e-mails e mensagens que estava recebendo do Sabores. Ao reclamar para o Encarregado de Proteção de Dados do Buffet que não havia consentido para o envio dos e-mails e das mensagens, Sueli teve como resposta que no contrato que ela assinou com o Buffet Sabores para a realização do seu noivado havia uma cláusula que permitia o envio das mensagens. Dessa maneira, argumentou o Encarregado, embora não houvesse o consentimento expresso, a LGPD autoriza o tratamento de dados para a execução de contratos, o que tornava as ações de divulgação compatíveis com a Lei. O Encarregado ainda explicou que a LGPD autoriza o tratamento de dados em dez hipóteses, nove, entre elas a execução de contrato, não necessitam de consentimento. Insatisfeita com a resposta, Sueli procurou o seu escritório, especializado em proteção de dados pessoais, para orientá-la sobre o entendimento transmitido a ela pelo Encarregado de Proteção de Dados do Buffet Sabores.

3.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO III

No caso em análise, o Buffet Sabores incluiu uma cláusula contratual na qual o titular dos dados autoriza o tratamento dos dados pessoais para o envio de e-mail com a divulgação dos seus produtos e serviços. Sueli, que realizou a sua festa de noivado com o Buffet, ao questionar o Encarregado pelo envio de e-mails que ela não consentiu, ouviu que o Buffet pode enviar o e-mail mesmo sem o consentimento, pois há uma cláusula contratual que autoriza o envio. Dessa maneira, a atuação do Buffet está respaldada pelo artigo 7º, inciso V, da LGPD, que autoriza o tratamento de dados pessoais para a **execução de contrato**.

Equivoca-se o Encarregado com esta explicação. Não é porque existe uma cláusula contratual autorizando o tratamento de dados pessoais para fins de envio de e-mail marketing, como relatado no caso em tela, que a base legal de execução de contrato possa ser invocada. O **envio de e-mail marketing**, embora previsto no contrato, **não é necessário para a execução do contrato** firmado entre o Buffet Sabores e Sueli. Dessa maneira, a execução do contrato não pode ser usada para justificar o tratamento de dados pessoais de Sueli com a finalidade de envio de e-mail marketing.

Uma opção que o Buffet teria para o envio do e-mail Marketing para Sueli seria a utilização da base

Licenciado a: dssenna@gmail.com

legal **legítimo interesse**, dando à cliente a possibilidade de **opt-out**, ou seja, de se descadastrar da lista caso não deseje mais receber divulgação dos produtos e serviços do Sabores. Nesse caso, receber um e-mail marketing de um buffet que ela contratou recentemente os serviços está dentro do esperado pela cliente, passando pelo chamado “teste do susto”, ou seja, não seria uma surpresa para Sueli, ela não tomaria “um susto” se recebesse um e-mail marketing do Buffet Sabores. Está dentro das expectativas razoáveis de uma cliente que contratou recentemente os serviços do Buffet Sabores receber um e-mail com a divulgação de serviços e produtos do Buffet, ainda mais o e-mail contando com uma salvaguarda que é a opção de descadastramento do e-mail de Sueli da base de dados da empresa. Caso não deseje continuar, poderá se desligar da lista, sem maiores perturbações à sua privacidade e à proteção dos seus dados pessoais.

Outro ponto a se destacar é que se o Buffet quisesse utilizar a base legal consentimento para o envio do e-mail marketing, ela deveria estar destacada das demais cláusulas contidas no contrato, para, assim, atender ao disposto na LGPD. É fundamental que o titular dos dados, ao consentir, saiba exatamente sobre o que está consentindo.

Em resumo, a existência de uma cláusula contratual que autoriza o tratamento de dados de Sueli para o envio de e-mail marketing não significa que este tratamento esteja legitimado pela base legal de execução

Licenciado a: dssenna@gmail.com

de contrato. A utilização dessa base legal somente se justifica quando o tratamento dos dados é imprescindível para a execução do contrato, o que não é o caso. Também não é possível afirmar que houve consentimento da titular dos dados, porque o consentimento, quando está junto com outras cláusulas contratuais, deve estar destacado. Uma opção, como visto, seria a utilização do **legítimo interesse**, desde que atendidos os pressupostos da avaliação de legítimo interesse. Importante, por fim, como salvaguarda, que haja a possibilidade de *opt-out* para que Sueli possa se descadastrar da lista caso não deseje mais receber notícias dos produtos e serviços oferecidos pelo Buffet Sabores.

ESTUDO DE CASO IV

BASES LEGAIS E O RH



Licenciado a: dssenna@gmail.com

4.1 BASES LEGAIS E O RH

O setor de Recursos Humanos, o RH, é um espaço de intenso tratamento de dados, inclusive dados sensíveis e de crianças e adolescentes. Toda organização trata dados pessoais, nem que sejam dados dos seus colaboradores.

Desde o momento que uma empresa recebe o currículo de um candidato a uma vaga de emprego, por exemplo, o tratamento de dados já se inicia. Importante que a organização pense no tratamento de dados desde o seu início, homenageando o ***Privacy by Design***, ou seja, o princípio segundo o qual a proteção de dados deve ser pensada desde a concepção de um produto ou de um serviço.

Na rotina do RH, o tratamento dispensado aos currículos é um importante ponto de atenção. É comum em muitas organizações que os **currículos** cheguem de maneira desordenada, no *e-mail* dos colaboradores, entregues na portaria, cheguem por correio ou postados em plataformas próprias para esta finalidade. Os formatos dos currículos são variados, existindo, muitas vezes, informações desnecessárias à finalidade declarada, em afronta ao princípio da necessidade.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Para começar, só é possível tratar dados se houver uma **finalidade** declarada, que, neste caso, seria o preenchimento de uma vaga disponível na organização ou a elaboração de um cadastro de reserva, que pode ser útil em locais com alta rotatividade de colaboradores (*turn over*). Se não existe uma finalidade, não deve haver tratamento dos dados, portanto, talvez fosse melhor nem receber esses currículos. De nada adianta coletar antecipadamente currículos para uma vaga, em uma espécie de cadastro de reservas, se não for para um preenchimento em curto espaço de tempo. Caso contrário, quando chegar o momento do preenchimento da vaga muitos dados estarão desatualizados, violando o princípio da **qualidade dos dados**, previsto no artigo 6º, inciso V, da LGPD¹⁶.

Além disso, armazenar dados que não estão sendo utilizados aumenta desnecessariamente o risco da organização, isto sem falar nos custos para garantir a segurança dos dados. Por vezes, melhor do que o recebimento do currículo será solicitar o link do **currículo lattes**, se for um profissional da área acadêmica, como um professor universitário, ou do **LinkedIn**, caso se trate da área corporativa. Desse modo, a organização não assume a responsabilidade de armazenar esses dados, pois tratará apenas dados tornados manifestamente

¹⁶ Artigo 6º, V – “qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento”.

públicos pelo titular, no próprio ambiente da rede social em que foram disponibilizados e dentro da finalidade para a qual foram publicados.

Nesse caso, a responsabilidade de manter os dados atualizados será do próprio candidato. Se a organização optar pelo recebimento de currículos, seja em meio físico ou digital, importante disponibilizar um **modelo** que esteja adequado à LGPD, evitando a coleta de dados desnecessários ou que possam fomentar discriminações.

A **base legal** utilizada para o processo seletivo (fase pré-contratual) pode ser o **consentimento**, respeitadas as formalidades e especificidades estabelecidas pela LGPD, que são de responsabilidade do controlador. Outra opção de enquadramento que parece viável é a utilização da base legal prevista no **artigo 7º, inciso V**, da LGPD, que autoriza o tratamento de dados quando for necessário à realização de “[...] procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados”.

O enquadramento do tratamento de dados a uma base legal é parte essencial do programa de conformidade com a LGPD e deve considerar as **especificidades da situação concreta**. Importante que o controlador consiga justificar a razão pela qual, naquele contexto, optou por aquela base em detrimento de outra também aparentemente cabível.

Fundamental informar ao candidato participante do processo seletivo todo o fluxo de tratamento dos seus

Licenciado a: dssenna@gmail.com

dados, homenageando a **autodeterminação informativa**, um dos fundamentos da LGPD (art. 2^a, II), a **boa-fé** e o **princípio da transparência**.

O tratamento de dados obedece a um **ciclo de vida**, motivo pelo qual o candidato deve ser informado do período no qual o seu currículo será mantido no banco de dados da organização, o que deve estar relacionado à finalidade para a qual foi coletado, ou seja, o preenchimento da vaga em aberto ou do cadastro de reserva. Caso a eliminação não ocorra ao término do processo seletivo que justificou a retenção do documento, importante fundamentar a razão. Se o candidato não foi selecionado para aquela vaga, mas já se sabe que será aberta outra para a qual o seu perfil profissional possui aderência, uma opção é coletar o seu **consentimento** para a manutenção do currículo no banco de dados para que possa concorrer à nova vaga. **Outra opção** é simplesmente orientar para que acompanhe a página de divulgação de vagas. Trata-se de decisão mais segura em termos de proteção de dados, embora possa não ser a melhor opção para a prospecção de novos talentos para a organização.

Durante a **vigência do contrato de trabalho**, a base legal que justifica boa parte do tratamento de dados do colaborador pela organização será a **execução do contrato** (art. 6º, V)¹⁷. Em algumas situações, a base

¹⁷ Artigo 7º, V – “quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados”.

legal pode ser o cumprimento de **obrigação legal ou regulatória pelo controlador** (art. 6º, II), como no repasse de informações ao e-Social, dentre outras exigências legais na seara trabalhista. Enquadrar os dados tratados em uma base legal é de **responsabilidade do controlador** e deve considerar as nuances, os detalhes do caso concreto, configurando importante etapa do programa de adequação à LGPD.

Mesmo com o **término** do contrato de trabalho, a organização pode continuar o tratamento de parte dos dados do agora ex-colaborador, especialmente aqueles que podem ser úteis para o **exercício regular de direitos** em eventual processo judicial (art. 7º, VI). Nesse caso, a base legal para a manutenção do tratamento dessa parcela dos dados deixa de ser a execução do contrato, que não existe mais, e passa a ser o eventual **exercício regular de direito em processo judicial** (art. 7º, VI)¹⁸.

Nota-se, na maior parte dos exemplos acima, que a alteração da finalidade levou à mudança da base legal autorizativa do tratamento de dados. Lembra-se, ainda, que dados para os quais não haja base legal autorizativa devem ser **eliminados**, pois o tratamento está violando a LGPD. Só é permitido o tratamento de dados nas hipóteses

¹⁸ Artigo 7º “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: [...] inciso VI, “para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).”

previstas na LGPD.¹⁹

Outro **ponto de atenção do RH** deve ser o compartilhamento de dados. O compartilhamento pode ser **interno** ou com empresas **terceiras**. Internamente o compartilhamento é necessário, por **exemplo**, para que o novo colaborador tenha acesso a um edifício, ao estacionamento da empresa ou para que a sua identificação funcional seja confeccionada. Mesmo se tratando de compartilhamento de dados com setores da própria empresa controladora, ele deve se restringir aos dados estritamente necessários para as finalidades declaradas. Além disso, o acesso aos dados compartilhados deve ser **restrito** às pessoas que, de fato, irão operacionalizar o tratamento.

O compartilhamento de dados pessoais dos colaboradores com empresas terceiras, que atuarão como **operadores ou controladores conjuntos**, pode ocorrer em situações variadas, como para proporcionar aos colaboradores alguns benefícios, como plano de saúde, vale-refeição, acesso à academia, entre outros. Nesses casos, quando não for necessário o consentimento, importante que o titular dos dados, no mínimo, esteja ciente desse compartilhamento.

¹⁹ Tratando-se de dados pessoais, as hipóteses nas quais o tratamento é autorizado estão descritas no artigo 7º da Lei; em se tratando de dados pessoais sensíveis, as bases legais são mais restritas e estão previstas no artigo 11 da LGPD.

Fundamental a existência de **contrato** entre o **controlador** e o **operador** de dados estipulando as obrigações e os limites da atuação do operador, o que será relevante para a apuração de descumprimento de ordens lícitas do controlador, que tornarão o **operador responsável** por eventual incidente. Contribuirá, também, para demonstrar, em homenagem ao **princípio da responsabilização** (art. 6º, X), o cuidado do controlador com os dados pessoais que está tratando.

Embora a LGPD não trate expressamente, como faz o GDPR, da exigência de contrato entre o controlador e o operador para o tratamento de dados pessoais, a ANPD, em seu **Guia Orientativo Para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**, deixou claro que se trata de **boa prática**. Sem a cláusula contratual estabelecendo os limites da atuação do operador fica mais difícil para o controlador demonstrar eventual descumprimento de suas ordens lícitas, o que atrai a responsabilidade solidária do operador, que normalmente não responde por eventuais incidentes²⁰.

²⁰ Artigo 42, § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o **operador** responde **solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as **instruções lícitas do controlador**, hipótese em que o **operador equipara-se ao controlador**, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei (sem grifos no original).

No caso de **controladoria conjunta**, a LGPD também prevê a **responsabilidade solidária**²¹. De acordo com a ANPD, a controladoria conjunta ocorre quando uma operação de tratamento envolve mais de um controlador²².

Muitos dados tratados pelo RH são considerados **sensíveis** pela LGPD, como exames admissionais, atestados médicos, informações sobre a filiação de colaboradores a sindicatos etc. Nesse caso, diante da maior proteção legislativa que os dados sensíveis receberam e das consequências mais lesivas ao titular dos dados decorrentes de eventuais incidentes, os cuidados precisam ser redobrados. O acesso aos dados sensíveis deve ser o mais **restrito** possível, estejam eles em meio físico ou digital. Deve-se dotar protocolos de segurança para evitar o compartilhamento indevido dos dados pessoais.

²¹ Art. 42. “O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - **o operador responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando **não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem **solidariamente**, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei” (sem grifos no original).

²² Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 12.

Destaca-se que nas **relações de trabalho** a utilização da base legal **consentimento** deve ser **evitada**. Isso porque fica difícil demonstrar que o consentimento foi livre – e o ônus disso é do controlador – quando há relação de subordinação, como ocorre nas relações trabalhistas.

Encerrada a relação de trabalho, os dados que não forem mais necessários para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou que não possam ser usados pelo controlador no exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral devem ser **eliminados**. Esses dados podem ser mantidos pelo tempo estipulado em lei ou regulamento. No silêncio da lei, o prazo de guarda deve ser equivalente ao de eventual questionamento judicial sobre aquele assunto. Na hipótese de demanda judicial na qual os dados possam ser usados como meio de prova, devem ser mantidos até o trânsito em julgado, isto é, até que o processo se encerre, não havendo mais possibilidade de interposição de recurso.

4.2 CASO IV – A DEMISSÃO DO JURANDIR

Em outubro de 2020, bem em meio à pandemia da Covid-19, Jurandir foi demitido da empresa em que trabalhava. Descontente com a situação, procurou o RH e solicitou a exclusão de todos os seus dados dos arquivos da empresa. Jurandir afirmou que não queria mais nada seu na empresa, que sabia dos seus direitos, pois a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais conferia a ele o direito de revogar a qualquer tempo o seu consentimento e solicitar o apagamento dos seus dados. Para a sua surpresa, Jurandir ouviu como resposta que mesmo ele revogando o seu consentimento a empresa não apagaria nenhum dos seus dados. Indignado com a resposta, Jurandir denunciou a empresa à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como técnico da ANPD responsável por este chamado, responda a Jurandir quais são os seus direitos neste caso, apresentando os fundamentos legais que sustentam a sua resposta.

4.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO IV

Jurandir, como titular de dados pessoais, tem o direito de exigir que a organização elimine os seus dados, já que o contrato de trabalho foi extinto. Contudo, isso não significa que a organização eliminará, de imediato, todos os dados que possui sobre ele. Isso porque há dados que ela pode necessitar manter para **cumprir obrigação legal** ou **regulatória** ou para **exercício regular de direito** em processo judicial. Caso Jurandir alegue, por exemplo, que realizou horas-extras sem a devida remuneração, a empresa necessitará dos registros de controle de sua jornada de trabalho para apresentar na sua defesa no processo judicial movido por ele.

Nesse caso, a organização **pode continuar tratando** esses dados referentes à jornada de trabalho pelo prazo em que pode ser cobrada judicialmente por eventuais inconsistências nas horas trabalhadas por Jurandir. O mesmo pode ocorrer com dados que a organização tem de manter para cumprir uma obrigação legal ou regulatória.

Na hipótese de Jurandir processar a empresa alegando, por exemplo, horas-extras não pagas, os dados referentes à jornada de trabalho poderão ser mantidos até o trânsito em julgado da decisão, isto é, até que não caiba mais recursos no processo.

Por outro lado, a **resposta apresentada pela Empresa**, de que não eliminaria nenhum dos dados de
Licenciado a: dssenna@gmail.com

Jurandir tratados por ela, **viola a LGPD**, pois com o término do contrato trabalho há dados do trabalhador que não são mais necessários. No caso concreto, portanto, os extremos devem ser evitados:

- (i) nem Jurandir tem direito de que todos os seus dados sejam excluídos;
- (ii) nem a Empresa tem o direito de manter a integralidade dos dados do ex-colaborador.

Sempre é necessário analisar a finalidade do tratamento e se há base legal que o justifique. Os dados que não se enquadrarem nessas diretrizes, devem ser eliminados, pois seu **ciclo de vida** se encerrou.

Em resumo, não é porque o titular tem autodeterminação informativa que todos os seus pedidos serão imediatamente atendidos, isto porque pode existir outra base legal que autoriza ou até mesmo obriga a continuidade do tratamento desses dados pessoais. Isso não quer dizer, como visto, que a Empresa possa manter a integralidade dos dados, já que o término do contrato retira de muitos dados a base legal que autorizava o tratamento, o que exige a sua eliminação.

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO V

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

5.1 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

A LGPD classifica algumas espécies de dados como **sensíveis** e atribui a eles uma camada extra de proteção. Essa **proteção adicional** é justificada pelo maior potencial que esses dados têm de revelar aspectos mais **íntimos** da personalidade humana, sem contar o elevado risco **discriminatório** de alguns desses dados.

A definição de dados sensíveis está prevista no artigo 5º, inciso II, da LGPD. **Dado pessoal Sensível é** o “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.

O tratamento de dados pessoais sensíveis é autorizado apenas nas hipóteses expressamente previstas no **artigo 11** da LGPD. A primeira hipótese é o **consentimento do titular**, que deve ser **específico, destacado** e para **finalidades específicas**.

Se a LGPD já impõe cuidado especial com a coleta do consentimento, com os dados pessoais sensíveis este cuidado deve ser redobrado. O termo de consentimento

Licenciado a: dssenna@gmail.com

deve ser redigido de maneira a ser compreendido pelo seu destinatário. Devem ser evitados termos técnicos e linguajar rebuscado, optando-se por pensar na **experiência do usuário**.

Em muitas situações, o uso de **recursos visuais**²³ pode contribuir para a elaboração de documentos que comunicam melhor ao titular dos dados o que ele está consentindo. Esse esforço do controlador em se comunicar com o titular de maneira transparente e efetiva, sem dúvida é uma demonstração de boa-fé que será considerada em seu favor pela ANPD ou pelo Poder Judiciário em caso de eventuais incidentes ou questionamentos.

Existem outras sete hipóteses nas quais o tratamento de dados sensíveis pode ser realizado **sem o consentimento do titular**, desde que isso seja **indispensável** para:

Art. 11, II [...]

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

²³ O uso de elementos do design no direito é desenvolvido por metodologias como o **Legal Design** e o **Visual Law**. Sobre o tema: FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; CALAZA, Tales (Coords.). **Legal Design: Teoria e Prática**. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021. SOUZA, Bernardo de Azevedo; OLIVEIRA, Ingrid Barbosa (Orgs). **Visual Law**: como elementos visuais podem transformar o direito. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

- c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
- d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
- e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou
- g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

O tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular somente pode ocorrer quando isto for **indispensável** para se atingir alguma das sete hipóteses mencionadas acima. Dessa maneira, se for possível atingir essas hipóteses sem tratar dados sensíveis, assim deve ser feito.

Observa-se que as bases legais de **execução de contrato, legítimo interesse e proteção crédito** não autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis. De outro lado, há expressa previsão legal de tratamento de dados sensíveis para a garantia de **prevenção à fraude**

Licenciado a: dssenna@gmail.com

e à segurança do titular “nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos”. É o caso, por **exemplo**, da autenticação biométrica nos caixas eletrônicos de bancos.

Ao tratar dados sensíveis, além de observar as hipóteses mais restritas de autorização para o seu tratamento, deve-se elevar à máxima potência os **princípios da prevenção e da segurança**, pois um incidente envolvendo dados sensíveis tem maior potencial lesivo aos direitos do titular dos dados, o que também potencializa a **responsabilidade** dos agentes de tratamento.

Reforça-se que antes de tratar dados sensíveis é **importante observar** se é possível atingir a mesma finalidade de maneira menos invasiva aos dados pessoais do titular. Há, por exemplo, certa banalização no uso de **dados biométricos**, que em muitas situações poderiam ser substituídos por alternativas menos intrusivas. Para o acesso a um estabelecimento, por exemplo, em vez do cadastro biométrico é possível a utilização de um cartão de acesso, uma senha ou outros meios de identificação menos invasivos e arriscados.

Como a privacidade deve ser pensada desde a concepção de um produto ou serviço (*Privacy by Design*) e deve ser o padrão operacional (*Privacy by Default*) em matéria de tratamento de dados, o **agente** de tratamento tem o **dever** de adotar as medidas mais protetivas aos

Licenciado a: dssenna@gmail.com

direitos dos titulares, razão pela qual se é possível atingir a finalidade do tratamento de maneira menos gravosa, assim deve ser feito.

Isso significa, por exemplo, que não é possível usar a biometria para autorizar o acesso à organização? Não. O importante é que a tomada de decisão em utilizar uma tecnologia de acesso seja precedida de análise cuidadosa a respeito, balanceando a segurança e a facilidade que a identificação biométrica pode trazer com os eventuais riscos à proteção dos dados pessoais dos titulares. Documentar esse processo decisório homenageia o **Princípio da Responsabilização**, demonstrando a boa-fé do agente de tratamento em encontrar uma solução de equilíbrio, sempre considerando a proteção de dados como um **padrão** operacional (*Privacy by Default*).

5.2 CASO V – ANIVERSARIANTES DO MÊS E RELIGIÃO

Você é o DPO da Empresa XYZ. Ao acompanhar o programa de implementação da LGPD na organização, você se deparou com um cadastro no RH que solicita a religião dos colaboradores. Querendo entender melhor o processo, você perguntou a Edirene, responsável pelo setor, qual o motivo da ficha cadastral dos colaboradores exigir essa informação, já que isso não era usual. Edirene respondeu que a empresa tem por hábito divulgar a lista de aniversariantes do mês, para que possam receber os cumprimentos dos seus pares em tão importante data. Ocorre que certa feita um colaborador reclamou da inclusão do seu nome, pois a sua religião não permitia comemoração do aniversário. Para evitar que casos como esse se repetissem, o RH passou a solicitar na ficha cadastral a religião do funcionário; caso fosse uma das religiões que orientava os seus integrantes a não comemorarem o aniversário, excluiria o seu nome da lista de aniversariantes do mês.

Instruções: Como DPO, analise as informações prestadas por Edirene. Explique as questões atinentes à LGPD previstas no caso. Apresente a solução.

5.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO V

Dados sobre a **religião** são considerados pela LGPD **dados pessoais sensíveis**. Como visto, o tratamento de dados sensíveis, embora autorizado em algumas situações mesmo sem o consentimento dos titulares, reveste-se de uma camada extra de proteção. Isso significa que se eu posso atingir a finalidade do tratamento de maneira menos gravosa, evitando o uso de dados sensíveis, assim eu devo proceder.

No caso em análise, a finalidade do tratamento do dado referente à religião do colaborador era evitar incluir na lista de aniversariantes do mês o colaborador que pertença a religião que não permita a comemoração de aniversários.

Como DPO da Empresa XYZ, Você deve orientar o RH que a coleta da religião no cadastro dos colaboradores, com a finalidade de evitar incluir na lista de aniversariantes do mês quem pertença à religião que não permite esse tipo de comemoração, **viola a LGPD**, em especial o **princípio da necessidade**. Os dados coletados devem ser apenas os **mínimos** necessários para que se atinja aquela finalidade. Em se tratando de dados sensíveis, essa regra é ainda mais restritiva, pois o artigo 11 da LGPD somente autoriza o tratamento de dados sensíveis em hipóteses excepcionais.

O RH da Empresa XYZ poderia atingir a mesma
Licenciado a: dssenna@gmail.com

finalidade perguntando ao colaborador se ele gostaria que o seu nome e dia de nascimento fossem incluídos na lista de aniversariantes do mês. Com isso, evitaria a coleta desnecessária de um dado sensível, respeitando os direitos dos titulares e a autodeterminação informativa, além de fomentar um ambiente plural e com respeito às diferenças, o que é salutar na formação de equipes.

Em resumo: no caso concreto, a coleta da religião para evitar incluir o nome do colaborador em lista de aniversariante do mês não é medida adequada, pois **ferre o princípio da necessidade**, já que se pode atingir a mesma finalidade de maneira menos gravosa à privacidade e à proteção dos dados dos titulares, bastando perguntar se ele deseja ser incluído na lista de aniversariantes (consentimento).

A LGPD também não autoriza tratamento de dados sensíveis nesse caso, pois a autorização é dada apenas quando isso for **indispensável** para se atingir a finalidade pretendida, o que, como visto, não é o caso, pois é possível não incluir o colaborador que não deseja participar da lista de aniversariantes do mês de maneira menos invasiva aos direitos dos titulares, bastando perguntar a ele se deseja participar da lista. A recusa não deve gerar nenhuma consequência desabonadora à colaboradora ou ao colaborador que assim decidiu, respeitando a sua **autodeterminação informativa**, bem como seus direitos e liberdades individuais constitucionalmente assegurados.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

ESTUDO DE CASO VI

DIREITO DOS TITULARES DIREITO DE REVISÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

6.1 DIREITO DOS TITULARES – DIREITO DE REVISÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS

Os titulares dos dados pessoais são os grandes destinatários da LGPD, que tem como um de seus fundamentos a **autodeterminação informativa**, isto é, o reconhecimento que o titular é quem deve decidir o que será feito com os seus dados. Os direitos dos titulares são materializações, concretizações dessa autodeterminação, dos demais fundamentos, como a privacidade, e dos princípios que regem a proteção de dados brasileira, como a finalidade, adequação, necessidade, transparência, prevenção e segurança, entre outros.

O **artigo 18** e seguintes da LGPD são os principais repositórios dos direitos dos titulares. O titular tem o direito de saber do controlador se os seus dados estão sendo tratados, de ter acesso aos dados, de retificá-los, revogar o consentimento, opor-se a tratamento realizado sem o seu consentimento, de solicitar a eliminação dos dados tratados, de levar os seus dados para outro controlador, exercendo o direito de **portabilidade**.

O titular tem direito de saber dos agentes de tratamento se os seus dados foram compartilhados e com

Licenciado a: dssenna@gmail.com

quem. O titular dos dados tem o direito de requerer a **revisão** de decisão que o afete e que foi tomada unicamente por mecanismo **automatizado**. A revisão pode ser feita por outro algoritmo, não havendo a exigência de que seja realizada por **seres humanos**, como ocorre no GDPR (artigo 22º, 3)²⁴.

O direito de revisão é relevante para mitigar o risco de viés algorítmico, de discriminações provocadas por falhas na construção de algoritmos ou nos bancos de dados que os alimentaram. Originariamente a previsão no projeto de lei que deu origem à LGPD era que a revisão

²⁴ Artigo 22º Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis

1. O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.

2. O nº 1 não se aplica se a decisão:

a)For necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o titular dos dados e um responsável pelo tratamento;

b)For autorizada pelo direito da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento estiver sujeito, e na qual estejam igualmente previstas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos interesses do titular dos dados; ou

c)For baseada no consentimento explícito do titular dos dados.

3. Nos casos a que se referem o nº 2, alíneas a) e c), o responsável pelo tratamento aplica medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e legítimos interesses do titular dos dados, designadamente o direito de, pelo menos, **obter intervenção humana** por parte do responsável, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão.

4. As decisões a que se refere o nº 2 não se baseiam nas categorias especiais de dados pessoais a que se refere o artigo 9.º, nº 1, a não ser que o nº 2, alínea a) ou g), do mesmo artigo sejam aplicáveis e sejam aplicadas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos interesses do titular.

seria feita por pessoa natural, mas isso foi modificado, permanecendo o direito de revisão, mas sem exigir que seja feita por pessoa natural²⁵.

²⁵ Sobre viés algorítmico, conferir: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37677421>, acessado em 11 de dezembro de 2021, às 12h15min.

6.2 CASO VI – A *FINTECH* E O CARTÃO DE CRÉDITO DA JOSEFA

Josefa possui o cartão de crédito de uma *fintech* que não tem agência, atende os clientes exclusivamente por meio digital. Uma das facilidades oferecidas aos clientes é solicitar aumento de limite de crédito pelo próprio aplicativo, sem burocracia, 24 horas por dia, sete dias na semana. O algoritmo da *fintech* responde em segundos à solicitação dos clientes, aceitando ou negando o pedido. A análise é feita exclusivamente pelo algoritmo, sem qualquer intervenção humana. Depois de utilizar o cartão por mais de um ano, pagando sempre antes da data de vencimento, Josefa solicitou aumento no seu limite de crédito, pois entendia que o limite disponibilizado estava bem abaixo da sua renda. Com o seu excelente histórico de relacionamento, bom *score* de crédito no Serasa, pensou que a aprovação seria certa. No entanto, para sua surpresa, a solicitação não foi aprovada. Indignada, quis saber da *fintech* os critérios utilizados para se chegar à decisão automatizada que negou a sua solicitação. A *fintech* respondeu que não poderia revelar os critérios adotados na decisão, pois colocaria em risco o segredo comercial, que é a *alma* do seu negócio. Insatisfeita com a resposta, Josefa procurou o seu escritório, especializado em proteção de dados pessoais, para orientá-la sobre a resposta fornecida pela *fintech* e quais seriam os seus direitos.

Instruções: Analise as informações prestadas pela *fintech* à luz dos direitos dos titulares assegurados pela LGPD.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

6.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO VI

O caso em análise aborda o direito do titular de dados pessoais de revisão de decisões que afetem os seus interesses e que foram tomadas **exclusivamente com base em tratamento automatizado** de dados pessoais. O caso deixa claro que a decisão foi tomada unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, o que assegura a Josefa o direito de revisão da decisão, com base no **artigo 20** da LGPD²⁶.

Originariamente, tal qual no GDPR, previa-se que a revisão seria realizada por **pessoa natural**, porém o dispositivo não prosperou, razão pela qual não há obrigatoriedade de que a revisão seja realizada por seres humanos, podendo ser submetida a algoritmos especializados nesta tarefa.

É certo que a *fintech* não tem necessariamente que conceder o aumento de limite de crédito pleiteado por Josefa, porém o que está em discussão no caso não é isso, mas, sim, o direito de Josefa de receber “informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial” (art. 20, §1º, da LGPD).

²⁶ Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

Como a *fintech* se recusa a prestar as informações solicitadas, alegando que isso violaria o segredo comercial e industrial, a LGPD permite que **a ANPD realize auditoria** no algoritmo para a verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais, conforme disposto no **artigo 20, § 2º**: “Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais”.

O risco de **viés algorítmico** é elevado, seja porque o algoritmo pode ter sido criado de maneira enviesada, seja porque o banco de dados que o alimentou pode estar historicamente enviesado, reproduzindo preconceitos históricos que foram replicados pelo algoritmo. Leitura interessante sobre o tema é o livro **Algoritmos de Destruição em Massa**, da matemática estadunidense **Cathy O’Neil**, que elenca diversas situações de viés algorítmico e os perigos que representam²⁷. Na Netflix, o documentário **Coded Bias**²⁸ também ajuda a compreender o tema, trazendo entrevista com a própria Cathy O’Neil, mas tendo como protagonista **Joy Buolamwini**, fundadora da Liga de Justiça Algorítmica, *Algorithmic Justice League*, *AJL*²⁹.

²⁷ Cf. O’NEIL, Cathy. **Algoritmos de Destruição em Massa**. Editora Rua do Sabão, 2020.

²⁸ <https://www.netflix.com/br/title/81328723>

²⁹ Cf. <https://www.ajl.org/>

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO VII

AGENTES DE TRATAMENTO E A RESPONSABILIDADE POR INCIDENTES



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

7.1 AGENTES DE TRATAMENTO E A RESPONSABILIDADE POR INCIDENTES

A LGPD define como **agentes de tratamento** de dados pessoais o **Controlador** e o **Operador**. Embora o Encarregado também esteja descrito no Capítulo VI da LGPD, que é justamente o que tem como título “Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais”, não foi considerado agente de tratamento, conforme o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Lei, que estabelece que os agentes de tratamento são o controlador e o operador.

O **controlador** pode ser **pessoa natural**, que trate dados com finalidade econômica, ou **pessoa jurídica**, seja ela de direito público ou privado. Como **protagonista** entre os agentes de tratamento, cabe a ele as **decisões**, destacando-se a definição da finalidade do tratamento e o enquadramento na base legal que o autoriza. Em regra, também será o **responsável** por eventuais incidentes³⁰.

O **operador**, por sua vez, realiza o tratamento de dados pessoais em **nome** do controlador. Pode ser pessoa natural que trate dados no exercício de atividade

³⁰ Art. 5º, VI, da LGPD: “controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais”

econômica ou pessoa jurídica de direito privado ou de direito público³¹. O operador será **responsabilizado** por incidente no tratamento de dados se tiver desobedecido ordens lícitas do controlador ou desrespeitado a LGPD (art. 43, §1º, I)³².

Nota-se a importância da existência de **contrato**³³ entre o controlador e o operador que registre as instruções do controlador acerca do tratamento de dados pessoais, o que será de grande importância em caso de incidente, pois servirá de parâmetro para a apuração da responsabilidade do operador, que só ocorre se tiver descumprido as ordens lícitas do controlador ou a própria LGPD. Fora isso, a responsabilidade será do controlador.

³¹ Artigo 5º, inciso VII, da LGPD: “operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”.

³² Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o operador **responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando **descumprir as obrigações da legislação** de proteção de dados ou quando **não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

³³ A LGPD não traz expressa a obrigatoriedade de contrato entre controlador e operador, mas, na esteira do GDPR, que consagra o **data processing agreement**, a ANPD considera uma boa prática o contrato entre controlador e operador.

A conceituação dos agentes de tratamento gerou posições desencontradas nos primeiros meses de vigência da LGPD, o que levou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, a publicar um Guia Orientativo sobre o assunto, que será abordado com mais detalhes na análise do próximo tema, que retomará a temática dos agentes de tratamento, mas com outro recorte.

O Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado³⁴ também consagra as figuras da **controladoria conjunta** e dos **suboperadores**. O Guia destaca como uma das obrigações do operador “dar ciência ao controlador em caso de contrato com suboperador”³⁵.

A ANPD reconhece que embora a LGPD não conceitue o suboperador, “o tema pode ser utilizado como parâmetro de análise para compreensão de cadeias mais complexas de tratamento de dados”. De acordo com a ANPD, “**o suboperador é aquele contratado pelo operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador**”³⁶.

³⁴ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021.

³⁵ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 16.

³⁶ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 19 (grifos no original).

A ausência do conceito de suboperador na LGPD não impossibilita ou torna ilegal a sua existência, eis que “pode desempenhar a função de operador em subordinação a outro operador”. O Guia Orientativo esclarece que a relação direta do suboperador é com o operador, mas “independentemente dos arranjos institucionais entre operador e suboperador, para efeitos da LGPD, ambos podem desempenhar, a depender do caso concreto, a função de operador e responder perante a ANPD”³⁷.

Em resumo, o que distingue o controlador do operador é o **poder de decisão**, que é do primeiro. O operador trata dados em nome do controlador, embora possa decidir sobre **questões não essenciais** relacionadas ao tratamento de dados, como, por exemplo, qual o software será utilizado para atingir o que foi solicitado pelo controlador. A definição de quem será o controlador e o operador será feita a partir de cada tratamento, analisando o papel desempenhado pelos agentes de tratamento. Na prática, todo operador de dados, em algum momento, será considerado controlador, ainda que dos dados dos seus próprios colaboradores. A ANPD considera a existência de contrato entre controlador e operador uma boa prática, além de reconhecer a possibilidade de atuação de suboperadores.

³⁷ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 19.

7.2 CASO VII – A FOLHA DE PAGAMENTO DA PORTO GOLDEN

A Empresa Porto Golden contratou o Escritório XYZ Contabilidade para cuidar da folha de pagamento de seus colaboradores. Passado um ano do contrato com o XYZ, foi noticiado um incidente no qual vazaram os dados dos colaboradores da Porto Golden. A fonte do vazamento foi a Beta, empresa de armazenamento de dados em nuvem contratada recentemente pelo XYZ. A Beta não gozava de boa reputação no mercado, pois já havia passado por alguns incidentes, porém cobrava bem mais barato do que a Ômega, empresa anteriormente contratada pelo XYZ. No contrato firmado entre a Porto Golden e o XYZ, o armazenamento seria feito pela Ômega, empresa que há muito tempo prestava serviços para o Escritório XYZ, bastante reconhecida no mercado pela segurança proporcionada aos clientes. Aliás, este ponto foi crucial para que a Porto Golden contratasse o Escritório XYZ Contabilidade, pois os dados dos seus colaboradores seriam armazenados por uma das empresas mais seguras do mundo.

Com a Beta, nova contratada do XYZ, os dados referentes à remuneração de todos os colaboradores da Porto Golden vazaram. Destaca-se que embora o contrato entre o XYZ e a Porto Golden estabelecesse que o armazenamento dos dados seria feito pela Ômega e que os dados da Porto Golden não poderiam ser compartilhados

Licenciado a: dssenna@gmail.com

sem expressa e prévia anuência da Porto Golden, o XYZ não a comunicou da substituição da Ômega pela Beta, o que só veio à tona com a notícia do incidente.

Indignados com o acontecimento, um grupo de colaboradores da Porto Golden procurou um escritório que se apresentava ao mercado como especializado em proteção de dados para orientá-los sobre os seus direitos. Ouviram que na LGPD o responsável por eventual incidente era o controlador, que, no caso, era a própria Porto Golden, controladora dos dados pessoais dos seus colaboradores. O Escritório XYZ Contabilidade, como operador, não respondia por eventual incidente, muito menos a Beta, empresa de armazenamento em nuvem, que era apenas uma suboperadora, figura não reconhecida pela LGPD e que sequer tinha relação direta com a Porto Golden ou com seus colaboradores.

Instruções: à luz da LGPD, analise as informações prestadas pelo escritório aos colaboradores da Porto Golden.

7.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO VII

No caso apresentado, a Empresa Porto Golden é a controladora dos dados dos próprios colaboradores, cabendo a ela decidir, dentro dos limites estabelecidos pela LGPD, como serão tratados. O Escritório XYZ Contabilidade, na relação com a Porto Golden, é o operador, pois tratará os dados dos colaboradores da Porto Golden a partir das orientações lícitas estabelecidas em contrato no qual foram estipulados os parâmetros para a realização do tratamento de dados pessoais, inclusive com a especificação da empresa que seria responsável pelo armazenamento dos dados em nuvem, a Ômega, antiga parceira do XYZ e uma das organizações com maior prestígio no mercado.

Como regra, a LGPD estabelece que a **responsabilidade** pelo tratamento é do **controlador**, que responde por eventuais incidentes ocorridos durante o tratamento. No caso apresentado, porém, o Escritório XYZ descumpriu instruções lícitas da Porto Golden, trocando a empresa responsável pelo armazenamento dos dados em nuvem, em claro descumprimento de disposição contratual entre ambas. O XYZ não garantiu aos dados compartilhados pela Porto Golden a segurança que se podia razoavelmente esperar. Ao agir assim, atraiu para si a mesma responsabilidade que incide sobre os controladores, já que um operador que descumpriu as instruções lícitas

do controlador assume, ao menos para fins de **responsabilidade**, papel semelhante ao do controlador, devendo se responsabilizar pelos danos provocados.

A Ômega, empresa de armazenamento em nuvem, era **suboperadora**, autorizada pela Porto Golden para armazenar os dados dos seus colaboradores. A alteração de suboperador deveria ter sido precedida de autorização da Porto Golden, o que não ocorreu. A Porto Golden só soube da troca quando foi informada do incidente. Lembre-se que a escolha da Ômega se deu pela elevada reputação de que desfrutava no mercado. Ao compartilhar os dados dos colaboradores da Porto Golden com um suboperador não autorizado pela Porto Golden, o XYZ descumpriu instruções lícitas do controlador, atraindo para si a responsabilidade.

Em seu Guia Orientativo sobre os Agentes de Tratamento, a ANPD estabelece como uma das obrigações dos operadores é **dar ciência** ao controlador em caso de **contrato com suboperador**. No caso em análise, a questão é ainda mais grave, pois havia no contrato firmado entre o controlador e o operador a especificação do suboperador, a empresa Ômega, que seria responsável pelo armazenamento dos dados dos colaboradores da Porto Golden, compartilhados com o XYZ. Embora a LGPD não faça menção expressa aos suboperadores, a ANPD afirma que “a falta do conceito de suboperador na LGPD não impossibilita ou torna ilegal que ele exista ou

Licenciado a: dssenna@gmail.com

que tenha funções, competências e responsabilidade no ambiente de proteção de dados pessoais brasileiro”³⁸.

Do ponto de vista do titular dos dados, a responsabilidade entre a Porto Golden e o XYZ é **solidária**, o que significa dizer que qualquer uma delas pode ser acionada para responder pelos danos causados. No entanto, existindo a possibilidade de cobrar indenização do XYZ, esta provavelmente será a escolha dos colaboradores, pois a relação de emprego com a Porto Golden pode ser um elemento inibidor. O mais provável, portanto, é cobrarem do XYZ. De qualquer modo, caso a Porto Golden seja acionada, poderá, de maneira regressiva, cobrar do Escritório XYZ Contabilidade os valores pagos³⁹, já que descumpriu as suas **instruções lícitas, contratualmente firmadas**, ocasião em que passou a se responsabilizar pelos danos provocados pelo incidente⁴⁰. O XYZ, por sua vez, poderá cobrar os valores que eventualmente pagou por conta do incidente da Beta, responsável direta pelo incidente.

³⁸ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 19.

³⁹ Art. 42, § 4º, da LGPD: “Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso”.

⁴⁰ Art. 42, §1º, I “o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou **quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que **o operador equipara-se ao controlador**, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei” (sem grifos no original).

Embora a LGPD não estabeleça a **obrigatoriedade de contrato**⁴¹ entre o controlador e o operador definindo os limites do tratamento, como faz o GDPR², o caso em análise demonstra a importância de que isso seja feito, pois fica mais fácil para o controlador demonstrar o descumprimento de suas instruções lícitas, já que estarão inscritas no contrato. De igual maneira, amplia-se a **segurança**, a **prevenção** e a **responsabilização**, que são princípios da proteção de dados (art. 6º, VII, VIII e X da LGPD).

A ANPD reconhece que a LGPD não determina expressamente que o controlador e o operador firmem contrato sobre o tratamento de dados, mas o reconhece como uma boa prática, “uma vez que as cláusulas contratuais impõem limites à atuação do operador, fixam parâmetros objetivos para a alocação de responsabilidades entre as partes e reduzem os riscos e as incertezas decorrentes da operação”⁴³.

⁴¹ O Guia Orientativo da ANP sobre os Agentes de Tratamento, que será abordado no próximo tópico, é expresso ao tratar a existência do contrato entre controlador e operador como boa prática.

⁴² GDPR, artigo 4º, “3. O tratamento em **subcontratação** é regulado por **contrato** ou outro ato normativo ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros, que vincule o subcontratante ao responsável pelo tratamento, estabeleça o objeto e a duração do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as **obrigações e direitos do responsável pelo tratamento**. Esse contrato ou outro ato normativo estipulam, designadamente, que o subcontratante [...]”. (sem grifos no original).

⁴³ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 16.

Em resumo, o Escritório XYZ, ao trocar a empresa de armazenamento em nuvem que atendia as especificações contratuais com a Porto Golden por outra mais barata, que não oferecia a mesma segurança, atraiu para si a responsabilidade pelo incidente, que, em regra, é do controlador. Por sua vez, como **suboperadora**, a empresa Beta, responsável pelo incidente, poderá ser demandada, regressivamente, por quem pagar a conta pelo incidente. Para mudar a empresa de armazenamento, o XYZ deveria ter comunicado previamente a Porto Golden, eis que no contrato estabelecido entre eles o armazenamento seria feito pela empresa Ômega, pela elevada reputação de que desfrutava. Pode haver outros desdobramentos jurídicos por conta da violação contratual, mas transbordam os objetivos deste texto.

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO VIII

PODER PÚBLICO E OS AGENTES DE TRATAMENTO À LUZ DO GUIA ORIENTATIVO DA ANPD



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

8.1 PODER PÚBLICO E OS AGENTES DE TRATAMENTO À LUZ DO GUIA ORIENTATIVO DA ANPD

O início do processo de adequação do Poder Público à LGPD foi permeado de confusões sobre os agentes de tratamento. Alguns órgãos públicos consideraram o presidente ou a mais alta liderança como controladores de dados, enquanto os demais servidores, incluindo os estagiários, foram considerados operadores de dados pessoais. Houve, inclusive, ato formal de nomeação de servidor para exercer a função de operador.

Como a LGPD define o operador como alguém que trata dados pessoais em nome do controlador, alguns profissionais defenderam a distinção mencionada acima. No caso de um tribunal, por exemplo, o órgão diretivo seria o responsável pelas decisões sobre o tratamento de dados, enquanto as(os) demais servidoras(es), juízas(es) e estagiárias(os) tratariam dados em nome do tribunal, ou seja, seriam operadores de dados.

Para clarear o tema, no final de maio de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, publicou o seu **Guia Orientativo** para Definições dos Agentes

Licenciado a: dssenna@gmail.com

de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado⁴⁴. A ANPD esclareceu que o operador de dados é sempre alguém externo à organização. Se um servidor trata dados em nome do órgão público que é o controlador de dados, o faz como se fosse o próprio controlador. Não se trata, portanto, de um operador tratando dados em nome do controlador, mas de manifestação do próprio controlador.

O Guia Orientativo trouxe esclarecimentos relevantes, a começar da **importância do estudo do GDPR**, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, porque a ANPD esclareceu que se valerá de toda a tradição e experiência construídas em décadas de proteção de dados na Europa como parâmetro para a interpretação e aplicação da LGPD. No próprio Guia Orientativo sobre os Agentes de Tratamento a ANPD utilizou categorias do GDPR na interpretação da LGPD, mesmo sem previsão expressa. É o caso do contrato entre controlador e operador, que é obrigatório no GDPR, mas sem igual previsão na LGPD. A ANPD, embora admita que não está previsto na LGPD, considera o contrato uma boa prática, recomendando a sua adoção.

O caso proposto para este tema ilustrará essa problemática da definição dos agentes de tratamento, em seu contexto de aplicação. Na sequência, será apresentada a resolução proposta para o caso à luz das orientações da

⁴⁴ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021.

ANPD, proporcionando conhecimento atualizado sobre a matéria. Os contornos normativos gerais sobre os agentes de tratamento já foram objeto de análise na abordagem do estudo de caso anterior.

8.2 CASO VIII – O TRIBUNAL COMO CONTROLADOR DE DADOS

Um tribunal brasileiro elaborou uma minuta de resolução para a implementação da LGPD no âmbito do tribunal, na qual considerava o presidente do tribunal como controlador de dados pessoais, responsável por decidir o que seria feito com os dados tratados, enquanto os servidores seriam os operadores, já que tratavam dados em nome do tribunal. O teor da minuta gerou controvérsia no grupo de trabalho responsável pela adequação do tribunal à LGPD. Alguns integrantes concordavam com esse entendimento, reforçando que outros tribunais e o MP de alguns Estados tinham a mesma compreensão; outros, por sua vez, consideraram esse entendimento equivocado, pois quando o tribunal atua como controlador isso envolve a atuação de todos os seus servidores, que concretizam as ações de tratamento realizadas pela Corte.

Essa controvérsia motivou o tribunal a contratar a sua consultoria, especializada em proteção de dados pessoais, para analisar a minuta de resolução, principalmente os aspectos relacionados aos agentes de tratamento.

Instruções: analise a definição de agentes de tratamento sugerida pela proposta de resolução de adequação do tribunal à LGPD à luz do Guia Orientativo da ANPD sobre Agentes de Tratamento e Encarregado.

8.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO VIII

Em análise ao caso apresentado, a Consultoria entendeu que o controlador é o tribunal e o operador é alguém externo a ele, mas que trata dados em seu nome. Dessa maneira, servidores ou estagiários não podem ser considerados operadores de dados. Quando atuam em nome do tribunal, estão atuando como se fossem o próprio controlador, pois estão subordinados ao seu **poder diretivo**.

Durante a análise do caso pela Consultoria, a ANPD publicou o seu “**Guia Orientativo Para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**”, o que a levou a Consultoria a revisar o documento, incluindo as orientações da ANPD, que coincidiam com a posição previamente adotada no parecer.

Segundo a **ANPD**, “Não são considerados controladores (autônomos ou conjuntos) ou operadores os indivíduos subordinados, tais como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de trabalho de uma organização, já que atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento”⁴⁵.

⁴⁵ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 5.

A ANPD esclareceu que “No contexto de uma pessoa jurídica, a organização é o agente de tratamento para os fins da LGPD, já que é esta que estabelece as regras para o tratamento de dados pessoais, a serem executadas por seus representantes ou prepostos”⁴⁶. Para que não reste nenhuma dúvida, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados reforçou que o “operador deve ser uma entidade distinta do controlador”⁴⁷.

Dessa maneira, fica afastada a possibilidade de se considerar, como fez o tribunal no caso em análise, que servidores sejam considerados operadores, já que atuam subordinados ao controlador, representando-o. O operador, por sua vez, “atua de acordo com os interesses e finalidades definidos pelo controlador”⁴⁸.

Em resumo, o tribunal é o controlador dos dados pessoais e os seus servidores, colaboradores e estagiários atuam subordinados a ele, como seus representantes. Desse modo, servidor não pode ser confundido com operador de dados pessoais, que deve ser “uma entidade distinta do controlador”. Servidores, funcionários, estagiários do controlador não podem ser considerados operadores quando tratam dados seguindo as determinações do próprio controlador, a quem estão subordinados.

⁴⁶ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 6.

⁴⁷ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 6.

⁴⁸ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 6.

ESTUDO DE CASO IX

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA LGPD



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

9.1 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA LGPD

Para que a LGPD tenha **força normativa**, isto é, para que aquilo que ela prescreve altere a realidade da proteção de dados no Brasil, necessário que seja dotada de mecanismos **coercitivos**, como as **sanções administrativas**, previstas no artigo 52.

Destaca-se que o artigo 52 não entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, como ocorreu com a maioria dos dispositivos da LGPD⁴⁹, mas apenas em **1 de agosto de 2021**. O adiamento da aplicação das sanções fez com que algumas organizações concluíssem, equivocadamente, que podiam esperar até agosto de 2021 para se adequarem à LGPD. No entanto, a LGPD já estava em vigor desde 18 de setembro de 2020, **obrigando** a todos os seus destinatários, isto é, pessoas naturais que tratem dados pessoais com finalidade econômica e pessoas jurídicas de direito público ou privado que tratem dados pessoais.

O adiamento das sanções administrativas da LGPD para agosto de 2021 não impediu que o agente de tratamento que violou a Lei a partir de 18 de setembro

⁴⁹ Lembre-se que os dispositivos relacionados à ANPD já estavam em vigor desde o final de 2018, embora a ANPD tenha sido constituída no final de 2020.

de 2020 fosse sancionado perante outras instâncias administrativas, como o PROCON, ou judicial, já que o princípio da **inafastabilidade da jurisdição**, previsto na Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, XXXV), estabelece que toda lesão ou ameaça a direito será apreciada pelo Poder Judiciário.

Desse modo, desde 18 de setembro de 2020 quem não se adequou à LGPD está em **desconformidade** com a Lei e sujeito a sanções judiciais e de outros órgãos administrativos. Desde 1 de agosto de 2021, todos os dispositivos da LGPD estão em vigor, sujeitando os infratores também às sanções administrativas previstas na LGPD, que podem ser aplicadas exclusivamente pela ANPD.

Contudo, para proporcionar mais **segurança jurídica** ao processo fiscalizador, a ANPD somente iniciará sua atuação sancionadora depois de aprovado o **Regulamento de Fiscalização e de Aplicação de Sanções Administrativas**. O Regulamento “estabelece as etapas do processo administrativo sancionador e os direitos dos administrados. A atuação da Autoridade pode se dar com relação a fatos ocorridos após 1º de agosto de 2021 ou para delitos de natureza continuada iniciados antes de tal data”⁵⁰.

⁵⁰ Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-administrativas-o-que-muda-apos-1o-de-agosto-de-2021>, acessado em 12 de dezembro de 2021, às 12h30min.

Para que não reste dúvida, violações à LGPD realizadas entre 18 de setembro de 2020 e 1º de agosto de 2021 podem ser sancionados por outros órgãos administrativos, como o Procon, o CADE, ou pelo Poder Judiciário, mas não estão sujeitas às sanções administrativas previstas na LGPD. Violações à LGPD realizadas depois de 1º de agosto de 2021 estão sujeitas às sanções da LGPD, mas a ANPD iniciará a sua atuação sancionatória apenas depois de publicado o seu Regulamento de Fiscalização e de Aplicação de Sanções Administrativas.

Suponha-se, por exemplo, que o Regulamento de Fiscalização entre em vigor em 28 de janeiro de 2022, homenageando o Dia Internacional da Proteção de Dados. A ANPD pode sancionar uma organização por uma violação ocorrida em setembro de 2021? A resposta é **sim**, pois em setembro de 2021 as sanções já estavam plenamente em vigor, o que ocorreu em 1º de agosto de 2021. Mas se a violação à LGPD foi realizada em 31 de julho de 2021, a ANPD não poderá sancionar a organização, porque nesta data as sanções ainda não estavam em vigor. As sanções podem atingir fatos iniciados antes de 1º de agosto de 2021, apenas se forem **delitos continuados**, que perdurem até depois desta data.

Em síntese, delitos praticados antes de 1º de agosto de 2021 não estão sujeitos às sanções previstas na LGPD, exceto se continuaram depois desta data. Violações praticadas depois de 1º de agosto de 2021 podem ser

Licenciado a: dssenna@gmail.com

sancionadas pela ANPD, com as sanções previstas no artigo 52, mas apenas depois que o Regulamento de Fiscalização e de Aplicação de Sanções Administrativas estiver em vigor.

As **sanções administrativas** previstas no artigo 52, que vão de uma advertência, passando por multas que podem chegar a R\$ 50 milhões de reais, a depender do faturamento da organização ou do grupo econômico no Brasil, culminando com a possibilidade de proibição do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

O artigo 52 traz o rol de sanções que podem ser aplicadas pela ANPD, começando pela advertência, multa simples ou diária, publicização da infração, bloqueio ou eliminação dos dados (incisos I a VI)⁵¹.

As sanções mais **graves**, que estão nos **incisos X, XI e XII** do artigo 52, somente podem ser aplicadas em caso de **reincidência** e desde que a sanção aplicada na primeira violação à LGPD não tenha sido a de **advertência**. Se houve reincidência, isto é, se a organização violou novamente a LGPD em ponto que já havia sido punida, estará sujeita, a depender da análise do caso concreto pela ANPD, às sanções previstas nos incisos X, XI e XII do artigo 52, da LGPD, desde que, acentua-se, a primeira sanção aplicada não tenha sido a de **advertência**.

⁵¹ Os incisos VII, VIII e IX do artigo 52 foram vetados e os vetos mantidos pelo Congresso Nacional.

Ainda com relação às sanções do artigo 52, X, XI e XII a LGPD estabelece que “em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias”, estas sanções somente serão aplicadas após ouvidos esses órgãos⁵². Diante disso, por exemplo, para que uma empresa aérea, que está sujeita à **competência sancionatória da ANAC**, seja punida com as sanções do artigo 52, X, XI e XII, além da reincidência específica e da punição anterior ser diversa da advertência, a ANAC também deverá ser ouvida sobre a aplicação da sanção. Contudo, como a ANPD tem a **palavra final** na esfera administrativa sobre proteção de dados, será dela a última palavra sobre a aplicação ou não da sanção. A ANPD está obrigada a ouvir a ANAC, mas não está obrigada a seguir o entendimento por ela manifestado. Parece adequado, no entanto, que se a ANPD discordar do entendimento da ANAC, que esclareça em sua **fundamentação** as razões que a fizeram não acatar o entendimento do órgão com competência sancionatória.

O **Poder Público** está sujeito às sanções administrativas do artigo 52, **exceto as pecuniárias**, isto é, a multa simples e a multa diária. Embora as restrições às sanções aplicadas ao Poder Público pela LGPD sejam apenas essas, na prática, outras sanções também

⁵² Art. 52, §6º, As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do **caput** deste artigo serão aplicadas: I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do **caput** deste artigo para o mesmo caso concreto; e II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos.

parecem **inaplicáveis**, pois uma sanção de proibição do tratamento de dados por seis meses, por exemplo, violaria o **princípio da continuidade do serviço público**, em prejuízo da própria população.

A ANPD esclarece que a LGPD também prevê a **responsabilização dos agentes públicos**, “nos termos previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Estatuto do Servidor Público), na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa) e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)”⁵³.

⁵³ Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-administrativas-o-que-muda-apos-lo-de-agosto-de-2021>, acessado em 12 de dezembro de 2021, às 12h45min.

9.2 CASO IX – O VAZAMENTO DE DADOS DA MIX TELECOM

A empresa Mix Telecom oferece aos seus clientes serviço de telefonia fixa, móvel e acesso à internet. Em 10 de agosto de 2022, a Mix Telecom sofreu um grande vazamento de dados de sua base de clientes, provocado por falhas em seu sistema de segurança da informação. Por esse episódio, a Mix foi multada pela ANPD em dez milhões de reais. Suponha-se que à época já estava em vigor o Regulamento de Fiscalização e de Aplicação de Sanções Administrativas da ANPD. Passados alguns meses, em maio de 2023, a Mix Telecom comunicou à ANPD e aos titulares dos dados novo incidente, idêntico ao anterior. As mesmas falhas de segurança que provocaram o primeiro incidente estavam presentes no segundo.

Diante da reincidência, a ANPD sancionou a Mix Telecom com a “suspensão parcial do funcionamento do banco de dados afetado pelo incidente, pelo período de três meses”. Durante o processo administrativo instaurado para apurar a responsabilidade da Mix Telecom pelo incidente, a ANPD ouviu a ANATEL, agência reguladora da área de telefonia, que tem competência sancionatória sobre a Mix Telecom. O parecer da ANATEL foi contrário à aplicação da suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, por considerá-la desproporcional à infração, prejudicando o atendimento aos clientes e a

continuidade da operação. A ANPD, no entanto, discordou desse entendimento e manteve a aplicação da sanção. Os advogados da Mix Telecom consideraram a decisão da ANPD ilegal, pois não poderia sancionar a empresa com parecer contrário da ANATEL, agência reguladora com competência sancionatória na área de telefonia.

Instruções: como consultoria especializada em proteção de dados, seu escritório foi procurado pela Mix Telecom para analisar a sanção aplicada pela ANPD à empresa.

9.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO IX

Primeiramente, o caso foi ambientado a partir de agosto de 2021, ocasião em que as sanções administrativas da LGPD já estão em vigor. Deve-se considerar que o Regulamento de Fiscalização e de Aplicação de Sanções Administrativas da ANPD também já estava em vigor. No primeiro incidente, a Mix Telecom sofreu a sanção de multa simples de R\$ 10 milhões de reais. Alguns meses depois, em maio de 2023, a empresa **reincidiu**, passando por incidente idêntico ao anterior.

Como estamos diante de um caso de reincidência e na primeira infração a sanção aplicada foi de multa simples, ou seja, uma sanção diversa da advertência, abre-se à ANPD a possibilidade de aplicar à Mix Telecom uma das sanções do artigo 52, incisos X, XI e XII. A sanção aplicada foi a do inciso X, ou seja, de “suspensão parcial do funcionamento do banco de dados afetado pelo incidente, pelo período de três meses [a suspensão poderia durar até seis meses]”.

Em razão da gravidade de que estão revestidas, a aplicação dessas sanções exige a reincidência e que a sanção aplicada na primeira infração não tenha sido **advertência**⁵⁴. Mas há outra peculiaridade no caso. A

⁵⁴ Art. 52, § 6º: As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do **caput** deste artigo serão aplicadas: I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do **caput** deste artigo para o mesmo caso concreto.

Mix Telecom, como empresa de telefonia, está sujeita à **competência sancionatória** da ANATEL, agência reguladora para o setor de telecomunicações. Diante disso, para que seja aplicada a sanção de suspensão parcial do funcionamento do banco de dados afetado pelo incidente **a LGPD exige** que a ANATEL seja ouvida previamente⁵⁵.

Embora a ANPD seja obrigada a ouvir a ANATEL sobre a aplicação da sanção em análise, **a palavra final será da ANPD**, instância máxima na esfera administrativa em matéria de proteção de dados pessoais. O artigo 55-J, que trata das competências da ANPD, em seu inciso XX, é cristalino ao estabelecer que compete à ANPD “deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos”.

No entanto, se a ANPD optou por não seguir a orientação da ANATEL, parece razoável que na sua **fundamentação presente as razões pelas quais optou por sancionar** a Mix Telecom, mesmo diante de parecer contrário da ANATEL.

Na aplicação da sanção à Mix Telecom, deve-se observar a questão da continuidade da prestação do serviço de telefonia, sob pena dos usuários serem mais impactados pela punição do que a empresa.

⁵⁵ Art. 52, § 6º: “As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do **caput** deste artigo serão aplicadas: [...] II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos”.

Observamos que ainda não há orientação da ANPD a esse respeito, portanto o **entendimento** adotado pela Autoridade pode ser **diverso**. O posicionamento ora adotado nos parece, salvo melhor juízo, harmônico com uma interpretação sistemática da Lei.

Destaca-se, por fim, que o entendimento neste caso é pela **possibilidade de aplicação da sanção pela ANPD**, mesmo contra o parecer da ANATEL, pois se trata da autoridade máxima em matéria de proteção de dados na esfera administrativa. Como o caso é de **reincidência** e a primeira sanção não foi de advertência, mas, sim, de multa simples, cumpre-se o requisito para a aplicação da sanção do artigo 52, X.

Destaca-se que esta resposta não considera o mérito da aplicação da sanção, inclusive porque não há elementos no caso para a sua aferição. O que interessa aqui é demonstrar o **cumprimento dos requisitos** para a aplicação da gravosa sanção do artigo 52, X:

- a) reincidência na mesma infração;
- b) sanção de multa simples pela primeira infração e não de advertência;
- c) como se trata de controlador submetido a outro órgão com competência sancionatória, no caso a ANATEL, a Agência foi previamente ouvida.

ESTUDO DE CASO X

A COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES À ANPD E AOS TITULARES



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

10.1 A COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES À ANPD E AOS TITULARES

A LGPD obriga o controlador a **comunicar** à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, **ANPD**, e aos **titulares** dos dados afetados a ocorrência de incidente de segurança “que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares” (art. 48).

A comunicação deve ocorrer o quanto antes, no menor intervalo possível, contado do momento em que o controlador soube do incidente. A Lei estabelece que a comunicação deve ser feita em **prazo razoável** (art. 48, §1º)⁵⁶, porém estabelece que a comunicação deve trazer o **motivo da demora**, caso não tenha sido feita **imediatamente** (art. 48, §1º, inciso V)⁵⁷.

⁵⁶ A ANPD recomenda que a comunicação seja feita em até dois dias úteis. Disponível em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca>, acessado em 13 de dezembro de 2021, às 15h10min.

⁵⁷ Art. 48. O **controlador** deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. § 1º A comunicação será feita em **prazo razoável**, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo: I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II - as informações sobre os titulares envolvidos; III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial; IV - os riscos relacionados ao incidente; **V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata**; e VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo (sem grifos no original).

A ANPD está em processo de regulamentação dos procedimentos para a comunicação de incidentes, mas, preliminarmente, já apresentou orientações e estabeleceu um formulário para a comunicação de incidentes. Quanto ao prazo para a comunicação de incidentes, a ANPD recomendou **dois dias úteis**, contados da data em que o controlador soube do incidente⁵⁸.

Embora a **obrigação** de comunicar o incidente seja do **controlador**, a ANPD estabeleceu que se forem excepcionalmente apresentadas pelo operador, serão devidamente analisadas pela Autoridade⁵⁹.

Importante que o **contrato entre o controlador e o operador** sobre o tratamento de dados tenha cláusula que estabeleça o **dever de comunicar** eventual incidente imediatamente ao controlador. Dessa maneira, a ausência de comunicação implicará no descumprimento de ordem lícita do controlador, com as consequências legais daí advindas.

Embora a LGPD não estabeleça expressamente a **obrigatoriedade de contrato** entre o controlador e o operador, trata-se de **boa prática**, já reconhecida expressamente pela ANPD. Assim, se o controlador optar

⁵⁸ Cf. <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca>, acessado em 6.06.2021, às 20h53min.

⁵⁹ “Embora a responsabilidade e a obrigação pela comunicação à ANPD sejam do controlador, caso excepcionalmente sejam apresentadas informações pelo operador, serão devidamente analisadas pela ANPD”. Cf. <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca>, acessado em 6.06.2021, às 20h57min.

por não estabelecer o contrato, atrairá para si risco desnecessário, além de criar obstáculo para a **responsabilização** do operador por eventual descumprimento de suas ordens lícitas, uma das hipóteses em que a LGPD permite que o operador seja responsabilizado pelo incidente. Se não há registro das ordens lícitas do controlador, que poderiam se materializar no contrato, fica mais difícil demonstrar que ele descumpriu essas ordens, restando apenas a segunda possibilidade de responsabilização, que é o descumprimento da LGPD.

Comunicado do incidente, o controlador deverá, caso o incidente se enquadre nas hipóteses de **comunicação obrigatória** à ANPD e aos titulares dos dados, comunicá-los imediatamente ou, no mais tardar, se a comunicação imediata não for possível, em até **dois dias úteis**.

Em caso de **dúvida** sobre a pertinência ou não da comunicação à ANPD e aos titulares, a recomendação da Autoridade é que a **comunicação seja feita**. Desse modo, o controlador só não comunicará o incidente quando tiver **certeza da desnecessidade**: se ficou em **dúvida** se é necessário comunicar, **comunique**. Quanto antes o incidente for comunicado maiores as possibilidades de **mitigação dos riscos** e dos **danos**. Por **exemplo**: se houve vazamento de dados do cartão de crédito do titular, se ele é avisado imediatamente, cancela o cartão evitando o seu uso indevido, aborrecimentos e prejuízos daí decorrentes.

A comunicação à ANPD pode ser **parcial** e complementada depois. Se o agente de tratamento já detectou o incidente e viu que é caso de comunicação, mas ainda está apurando para saber as suas origens e extensão, já pode comunicar à ANPD que ele ocorreu e informar que está apurando e complementará a comunicação posteriormente, trazendo mais detalhes. Tanto é assim que no próprio formulário disponibilizado pela ANPD para comunicação de incidentes o agente de tratamento (normalmente o controlador) deve informar se a comunicação é **parcial** e, neste caso, se ela é **preliminar ou complementar**.

A ANPD pode solicitar informações complementares a qualquer tempo. Quanto mais transparente o controlador for neste processo de comunicação à ANPD, maior será o impacto positivo disso na **minimização** de eventual sanção.

A ANPD disponibiliza um **formulário** em sua página na internet, que deve ser preenchido com as informações sobre o incidente. Importante que o DPO e o comitê de respostas a incidentes tenham bastante familiaridade com este documento, inclusive já catalogando informações gerais necessárias ao seu preenchimento.

A comunicação do incidente é feita por meio de **peticionamento eletrônico**. Como o **prazo** para liberação do cadastro de usuário externo para peticionamento é de até **três dias úteis** e o prazo sugerido pela ANPD

Licenciado a: dssenna@gmail.com

para comunicação do incidente é de até **dois dias úteis**, importante que esse cadastro seja feito com antecedência para evitar o inconveniente de não conseguir comunicar o incidente no prazo em razão da não liberação tempestiva do cadastro do usuário.

Se você está iniciando a adequação de uma organização, **recomende** que o cadastro do responsável pela comunicação seja feito imediatamente. As orientações para o cadastramento de usuários podem ser acessadas no link que está disponível nesta nota de rodapé⁶⁰.

Na **comunicação**, o agente de tratamento deve **informar** se ela é **completa** ou **parcial**, se for parcial, se é **preliminar** ou **complementar**. A ANPD deve ser informada se há risco ou dano relevante aos titulares ou se isso ainda não foi apurado. Deve ser informado se o **comunicante** é o controlador (regra) ou o operador (exceção); se for o operador, deve informar se já comunicou ao controlador. Dados do agente de tratamento, dados do notificante e do encarregado (DPO); se o notificante for o próprio DPO, basta sinalizar, sem que haja necessidade de duplicar as informações.

Finalizada esta etapa geral do formulário de comunicação, o agente de tratamento passa a trazer as **informações mais específicas** sobre o **incidente**.

⁶⁰ https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/centrais-de-conteudo/manual_usuario_externo_sei_atualizado.pdf

I. **DESCRIÇÃO DO INCIDENTE**

- a) resumo de como ocorreu;
- b) quando ocorreu;
- c) quando a organização teve ciência do incidente;
- d) como teve ciência;
- e) se a comunicação não foi feita em dois dias úteis, os motivos de isso não ter ocorrido;
- f) se o incidente não foi comunicado de forma imediata, os motivos da demora;
- g) natureza dos dados afetados, basicamente se são sensíveis ou não;
- h) quantidade de titulares afetados;
- i) categoria dos titulares (funcionários, clientes, usuários etc.).

II. **MEDIDAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO TOMADAS**

Descrito o incidente, o agente de tratamento informará as **medidas de segurança e prevenção tomadas**:

- a) quais medidas de segurança, técnicas ou administrativas foram tomadas para prevenir a ocorrência do incidente;

Licenciado a: dssenna@gmail.com

- b) quais medidas tomadas após a ciência do incidente;
- c) quais medidas serão tomadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo do incidente aos titulares;
- d) o agente de tratamento realizou o RIPD.

III. **RISCOS RELACIONADOS AO INCIDENTE**

Por fim, a ANPD questiona os **riscos relacionados ao incidente**, indagando:

- a) as prováveis consequências do incidente para os titulares;
- b) se pode haver consequências **transfronteiriças**;
- c) se os titulares foram comunicados e, em caso negativo, os motivos de isso não ter sido feito ou do seu atraso.

Anota-se, uma vez mais, a importância de que o conteúdo do **Formulário de Comunicação de Incidentes de Segurança com Dados Pessoais** seja de amplo conhecimento de todos, especialmente dos que trabalham mais diretamente com o tema na organização, em especial o Encarregado (DPO) e os **comitês de proteção de dados** e de **respostas a incidentes**.

O formulário reforça a importância da **prevenção** e de **registrar** todas as medidas adotadas em robustas **trilhas de auditoria**, que poderão se transformar nas evidências que demonstrarão à ANPD o compromisso do

agente de tratamento com a proteção dos dados pessoais que estão sob sua responsabilidade. Sem dúvida, isso será considerado positivamente na aplicação de eventual sanção⁶¹.

⁶¹ Art. 52, § 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; II - a **boa-fé do infrator**; III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; IV - a condição econômica do infrator; V - a reincidência; VI - o grau do dano; VII - a **cooperação do infrator**; VIII - a **adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano**, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei; IX - a adoção de **política de boas práticas e governança**; X - a pronta adoção de medidas corretivas; e XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção (sem grifos no original).

10.2 CASO X – O INCIDENTE DE SEGURANÇA DO BANCO VERDE

O Banco Verde detectou um incidente de segurança envolvendo os dados pessoais de milhares dos seus correntistas. Detectado o incidente, a área de segurança da informação comunicou imediatamente ao comitê de gerenciamento de incidentes. Em análise preliminar, constatou-se que o incidente era de grandes proporções e atingia fortemente os titulares dos dados pessoais, revelando dados de comprovação de identidade oficial e dados financeiros, violando o sigilo bancário. Moacir, integrante do comitê de gerenciamento de incidentes, sustentou que deveriam coletar todas as informações possíveis, elaborar um relatório minucioso e completo, com todos os aspectos do incidente e, então, comunicar à ANPD e aos titulares dos dados. Sustentou que era importante que já apresentassem informações completas sobre o incidente, pois depois de aberto o requerimento para prestar informações à Autoridade ele não poderia mais ser retificado ou complementado. Cléber, integrante do Comitê, informou que como a LGPD estabelece que a comunicação deve ser feita em prazo razoável, ele considerava que, diante da abrangência do caso, eles poderiam comunicar em 15 dias úteis, que seria um prazo razoável para o levantamento de todas as informações. Deise, responsável pela área de segurança da informação e integrante do Comitê, informou que o incidente foi

Licenciado a: dssenna@gmail.com

provocado por um *bug* no sistema operacional, que, por uma falha interna, não foi devidamente atualizado. Com a instalação do *patch* fornecido pela desenvolvedora do sistema operacional a falha foi corrigida. Deise achou importante reportar a falha e a correção na comunicação feita à ANPD.

Instruções: como Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do Banco Verde, durante a reunião foi solicitado que Você analisasse o caso à luz das informações e posicionamentos suscitados na reunião.

10.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO X

No caso em análise, o Banco Verde detectou o incidente e que era de grandes proporções, com severo impacto para os titulares dos dados. Moacir, colaborador do banco que integrava o comitê de gerenciamento de incidentes, muito zeloso de suas atribuições e sabendo da gravidade do episódio, sugeriu que somente contatassem a ANPD depois de coletarem todas as informações e elaborarem um relatório minucioso. De acordo com Moacir, isso seria necessário, pois uma vez feita a comunicação à ANPD, ela era definitiva, não permitindo complementação posterior.

A informação repassada por Moacir não procede. A comunicação do incidente pode ser feita de maneira **parcial e complementada** posteriormente. A sugestão de Moacir parece boa, mas, na prática, atrasaria sobremaneira a comunicação à ANPD e aos titulares, elevando significativamente o risco para a organização. O recomendado, neste caso, é assim que ficou sabendo do incidente e da gravidade já comunicar à ANPD, com as informações que estão disponíveis naquele momento e complementá-las posteriormente. Quanto melhor o trabalho de adequação à LGPD tiver sido feito, maior serão as informações de qualidade à disposição do controlador para fundamentar a comunicação do incidente à ANPD.

Cléber, outro integrante do Comitê, defendeu que
Licenciado a: dssenna@gmail.com

poderiam fazer a comunicação do incidente em até quinze dias. A LGPD fala em prazo razoável, sustentou Cléber, o que, no seu entender, diante das peculiaridades do caso, seria de quinze dias. Equivoca-se Cléber, pois a ANPD já se manifestou que considera dois dias úteis um prazo razoável. Na comunicação do incidente, já será possível informar à ANPD que a causa do incidente foi descoberta e a sua correção providenciada, pois foi isso que ocorreu com a instalação do *patch* fornecido pela desenvolvedora do sistema operacional. Demonstrar que o problema já foi detectado e solucionado será importante na comunicação do incidente e mitigará eventual sanção, pois a “pronta adoção de medidas corretivas” é um dos parâmetros considerados na aplicação das sanções⁶².

Em resumo, a comunicação deve ser feita imediatamente ou, no máximo, em dois dias úteis. Pode ser parcial, com as informações levantadas até o momento, e complementada posteriormente.

⁶² Artigo 52, §1º, X, da LGPD.

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO XI

TRATAMENTO DE DADOS PELO PODER PÚBLICO



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

11.1 TRATAMENTO DE DADOS PELO PODER PÚBLICO

Andou bem o legislador ao incluir as pessoas jurídicas de direito público no rol de organizações sujeitas à LGPD, haja vista o descomunal volume de dados tratados pelo Poder Público desde antes do nascimento até depois da morte da pessoa natural, nas mais diferentes esferas da vida. A existência de limites legais claros às atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pelo Poder Público é de grande importância para a efetividade do direito fundamental à proteção de dados pessoais.

A base legal específica para o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público está prevista no **artigo 7º, inciso III**, da LGPD, que autoriza a realização do tratamento de dados: “pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei”.

A autorização para tratamento de dados prevista no referido inciso tem como norte a **execução de políticas públicas** devidamente reguladas. Os contornos

Licenciado a: dssenna@gmail.com

do tratamento de dados pelo Poder Público estão previstos nos artigos 23 e seguintes da LGPD. O **artigo 23** esclarece que as pessoas jurídicas de direito público tratarão dados pessoais para o “atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o **objetivo** de **executar as competências legais** ou cumprir as **atribuições legais** do serviço público” (sem grifos no original).

Muitos profissionais de proteção de dados que se debruçam sobre o tratamento de dados realizado pelo Poder Público consideram a base legal do artigo 7º, inciso III, **insuficiente**, razão pela qual entendem que o artigo 23, especialmente no trecho acima transcrito, também traz hipóteses autorizativas de tratamento de dados pelo Poder Público.

De acordo com Wimmer, “o Estado desempenha um amplo rol de atividades de tratamento de dados que nem sempre podem ser compreendidas como políticas públicas”. A autora apresenta alguns exemplos de atividades necessárias ao funcionamento da máquina estatal, mas que não são classificáveis como políticas públicas, como o “pagamento de salários e gestão de servidores públicos” e as atividades de fiscalização e sancionamento⁶³.

⁶³ WIMMER, Miriam. **O Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**. in DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 280.

Outro exemplo de operação de tratamento realizada pelo Poder Público que não se enquadra na execução de política pública é o tratamento de dados realizado pelo Poder Judiciário no exercício de sua **função jurisdicional**. Embora não se adeque ao disposto no artigo 7º, inciso III, se encaixa no artigo 23, como hipótese de execução de uma competência legal do Poder Público⁶⁴.

Questiona-se, ainda, a possibilidade de o Poder Público tratar dados com fundamento em **outras bases legais** que não foram delineadas especificamente para ele, especialmente o consentimento e o legítimo interesse. Wimmer entende que isso só seria possível excepcionalmente, em especial em situações nas quais as relações “entre cidadãos e Poder Público se dá de maneira voluntária, por livre escolha do cidadão”. Wimmer destaca que “Embora a Lei não traga respostas claras quanto a essa questão, é interessante notar que, na experiência europeia, tem-se entendido que o Estado deve atuar predominantemente com base em suas competências legais específicas”. O GDPR veda o uso do legítimo interesse por autoridades públicas no desempenho de suas atribuições⁶⁵.

⁶⁴ PALHARES, Felipe; PRADO, Luis Fernando; VIDIGAL, Paulo. **Compliance Digital e LGPD**. Coleção Compliance, V. 5. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 193.

⁶⁵ WIMMER, Miriam. **O Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**. in DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 280.

A LGPD esclarece que os **serviços notariais e de registro** se submetem às regras de tratamento de dados previstas para o Poder Público ⁶⁶. **Empresas públicas e sociedades de economia mista**, por sua vez, quando tratam dados atuando em **regime de concorrência**, isto é, oferecendo produtos ou serviços que também são oferecidos ao mercado pelos seus concorrentes, devem se submeter às mesmas regras destinadas ao tratamento de dados das pessoas jurídicas de **direito privado particulares**; por outro lado, se estão atuando na operacionalização ou execução de **políticas públicas**, submetem-se às regras previstas para o tratamento de dados realizado pelas pessoas jurídicas de **direito público**⁶⁷.

A LGPD orienta que os dados que estão sob a guarda do Poder Público sejam mantidos em formato **interoperável**, facilitando o compartilhamento, nas hipóteses em que a Lei autoriza ⁶⁸. Interoperabilidade é a

⁶⁶ Art. 23, § 4º “Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei”.

⁶⁷ Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo.

⁶⁸ Art. 25. “Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral”.

capacidade dos sistemas conversarem entre si, facilitando o compartilhamento dos dados.

A LGPD restringe o compartilhamento de dados pelo Poder Público, que “deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei”⁶⁹. A transferência de dados a entidades privadas é vedada ao Poder Público, exceto nas hipóteses autorizadas pelo artigo 26, §1º, da LGPD⁷⁰.

Quando a LGPD autoriza ao Poder Público que comunique ou compartilhe dados com pessoa de direito privado, exige comunicação à ANPD e consentimento do

⁶⁹ Artigo 26 da LGPD.

⁷⁰ Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei. § 1º **É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:** I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação); II - (VETADO); III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei. IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. § 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional (sem grifos no original).

titular dos dados, exceto nas hipóteses excepcionadas pela Lei⁷¹.

A ANPD poderá solicitar do Poder Público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas e detalhes sobre o tratamento realizado, além de poder emitir parecer técnico complementar para assegurar o cumprimento da LGPD (art. 29).

Se o Poder Público violar a LGPD a ANPD poderá enviar informe com as medidas necessárias para fazer cessar a infração (art. 31). Por fim, a ANPD poderá solicitar a publicação de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, **RIPD**, bem como sugerir a adoção de padrões e boas práticas para tratamentos de dados pelo Poder Público.

No que diz respeito ao RIPD, há controvérsia na doutrina sobre a necessidade de **elaboração prévia** ou apenas quando solicitada a publicação pela Autoridade. Há quem defenda que somente se publica o que já existe, razão pela qual a melhor interpretação seria a publicação prévia. Outros, todavia, entendem que a Administração Pública atua em obediência à legalidade estrita, o

⁷¹ Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será **informado** à autoridade nacional e dependerá de **consentimento** do titular, **exceto**: I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei; II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.

que não ocorreria no caso em tela⁷². Essas questões serão resolvidas pela ANPD, no exercício do seu poder regulamentar.

Reitera-se que o objetivo deste texto não é esgotar ou aprofundar o tema objeto de estudo, mas apresentar elementos que possam ser úteis à resolução do caso proposto. Para saber mais, recomendamos a leitura dos dispositivos da LGPD sobre o tema, em especial os artigos 23 a 32, além das obras indicadas no rodapé, que contribuirão para o desenvolvimento dos estudos⁷³.

⁷² Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

⁷³ Conferir: DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (Coords.). **LGPD & Administração Pública: uma análise ampla dos impactos**. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 2020; PRUDENTE DO AMARAL, Luiz Fernando de Camargo. **Desafios da LGPD em Relação à Implementação pelo Poder Público**. In OPI-CE BLUM, Renato (Org.). **Proteção de Dados: desafios e soluções na adequação à Lei**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 77 a p. 92; TASSO, Fernando. **A Lei Geral de Proteção de Dados e os Tribunais – Desafios para Implementação**. In OPI-CE BLUM, Renato (Org.). **Proteção de Dados: desafios e soluções na adequação à Lei**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 63 a p. 76; WIMMER, Miriam. **O Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**. in DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 280;

11.2 CASO XI – EMPRESA PÚBLICA E VIOLAÇÃO À LGPD

Um banco constituído na modalidade de empresa pública federal foi denunciado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados por um grupo de correntistas, que possuíam conta corrente, cartão de crédito e outros produtos financeiros do banco. Em síntese, os correntistas alegaram que o banco público compartilhou indevidamente seus dados com uma empresa de seguro, que estava fazendo uso inadequado dos dados, para além do consentimento concedido ao banco. Provas robustas comprovaram os fatos narrados, não deixando dúvida à ANPD sobre o alegado. Ao discutir o caso em um curso de formação sobre DPO, Diocleciano, estudante do curso, afirmou aos colegas que como o banco é uma empresa pública federal poderá sofrer as sanções do artigo 52 da LGPD, exceto as pecuniárias, ou seja, não incidirá sobre ele a multa diária e a multa simples, que podem chegar a R\$ 50 milhões de reais. Essas sanções, alegou Diocleciano, não são aplicáveis ao Poder Público na hipótese de violação à LGPD. No entanto, destacou, isso não significa que ficará impune, já que há outras sanções na Lei, inclusive até mais severas do que as pecuniárias.

Instruções: analise as afirmações de Diocleciano à luz da LGPD. Fundamente o seu ponto de vista.

11.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO XI

Diocleciano está correto ao afirmar que **não incide** sobre as pessoas jurídicas de direito público as **sanções pecuniárias**, que são as sanções de multa simples e multa diária (art. 52, II e III da LGPD). Equivoca-se, no entanto, ao afirmar que no contexto apresentado o banco, por ser uma empresa pública federal, não possa sofrer sanções pecuniárias. No caso em análise, o banco está atuando no **regime de concorrência**, portanto está sujeito às mesmas regras aplicáveis às demais instituições bancárias. É assim que prescreve o artigo 24 da LGPD: “As **empresas públicas** e as sociedades de economia mista que atuam em **regime de concorrência**, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão **o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares**, nos termos desta Lei”.

O caso apresenta uma situação na qual houve o vazamento de dados de clientes bancários do banco público, que possuem conta corrente, cartão de crédito e outros produtos similares. Trata-se, portanto, de atuação do banco em **regime de concorrência**, oferecendo produtos que também são comercializados por outros bancos. Nesse caso, o banco público se sujeita às regras aplicáveis aos demais bancos, inclusive sanções pecuniárias. Em outras palavras, ele pode sofrer as sanções pecuniárias (multa simples ou multa diária) por

violação à LGPD, desde que sejam as punições adequadas ao caso.

Se o banco estivesse atuando como operador ou executor de políticas públicas, aí o tratamento seria igual ao destinado às pessoas jurídicas de direito público, o que impediria a aplicação de sanções pecuniárias, já que esta modalidade de sanção não se aplica ao Poder Público. Caso o compartilhamento indevido de dados fosse de clientes que receberam o Auxílio Emergencial no banco, a atuação seria de operacionalização ou execução de políticas públicas, sujeitando-o às regras destinadas às pessoas jurídicas de direito público, que proíbem sanções pecuniárias.

Em resumo, no caso apresentado, o banco pode ser multado, pois atua em regime de concorrência. Sujeita-se às mesmas regras que os bancos privados. Se a atuação fosse na execução de políticas públicas, não poderia ser multado, já que estaria sujeito às mesmas regras aplicáveis ao Poder Público, para o qual não se aplicam as sanções pecuniárias.

ESTUDO DE CASO XII

TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

12.1 TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

A LGPD cuidou de maneira diferenciada do tratamento de dados de crianças e adolescentes. A Lei esclarece que o tratamento de dados de criança e adolescente somente pode ser realizado no seu **melhor interesse**, nos termos da LGPD e da legislação pertinente, em especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em genuíno **diálogo das fontes**.

Quando a LGPD aborda o tratamento de dados de criança ela o condiciona ao **consentimento específico e destacado** da mãe, do pai ou de um responsável legal. A autorização pode ser individualmente da mãe ou do pai, sem a necessidade que se manifestem em conjunto.

Se houver divergência irreconciliável quanto à autorização, caberá ao Judiciário dirimi-la. É cada vez mais frequente a discordância entre familiares da criança sobre o grau de exposição que ela pode ter nas redes sociais, chegando ao Poder Judiciário. A **chave** para essa análise é considerar o melhor interesse da criança e os impactos que a exposição pode ter para o desenvolvimento da personalidade. Mesmo o consentimento da mãe, do pai

Licenciado a: dssenna@gmail.com

ou do responsável legal não pode se sobrepor ao melhor interesse da criança.

A LGPD exige que o consentimento seja **específico**, o que descarta a possibilidade de um consentimento genérico, uma espécie de “**cheque em branco**” para que o controlador trate os dados pessoais de uma criança. Para cada atividade de tratamento deve ser fornecido o consentimento específico da mãe, do pai ou responsável legal pela criança. **Por exemplo:** se a escola da criança deseja postar uma foto ou um vídeo de uma apresentação em uma rede social, deve solicitar o consentimento específico da mãe, do pai ou responsável legal pela criança. Quanto mais detalhes específicos sobre a apresentação estiverem descritos no termo de consentimento, melhor, demonstrando a boa-fé e transparência do controlador ao cuidar de temática tão delicada, como o tratamento de dados de criança.

Além de específico, o consentimento deve ser **destacado**, o que significa que não pode estar misturado com cláusulas que versem sobre outros temas. Para destacá-lo, ele pode estar escrito com fontes maiores, em negrito ou com cores que chamem a atenção. Se for adequado ao caso, a LGPD recomenda o uso de recursos **audiovisuais**, proporcionando informações simples, claras e acessíveis aos pais, responsável “e adequada ao entendimento da criança” (art. 14, §6º). Nesse ponto, a utilização do **legal design** ou **visual law** pode ser interessante para o cumprimento pleno do disposto

Licenciado a: dssenna@gmail.com

na Lei, além de demonstrar boa-fé e transparência ao se comunicar adequadamente com as crianças, suas mães, pais e responsáveis legais, em genuíno processo de **educação digital** e respeito à **autodeterminação informativa**.

A LGPD permite o tratamento de dados de criança sem o consentimento apenas em situações extremas, “[...] quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo” (art. 14, §3º).

Embora o consentimento pareça ser a **única base legal** para o tratamento de dados de criança, muitos estudiosos da matéria reconhecem outras hipóteses, como o tratamento para cumprimento de **obrigação legal** ou **regulatória**. É o caso do compartilhamento de dados dos estudantes com o MEC, no Censo da Educação, que independe do consentimento. Embora independa do consentimento, importante a comunicação da realização do tratamento dos dados pessoais da criança, reforçando os fundamentos e os princípios da proteção de dados pessoais previstos na LGPD.

Henriques, Pita e Hartung defendem que o tratamento de dados de crianças e adolescentes, pelas peculiaridades de que se revestem, guardam **relação** direta com o tratamento de **dados pessoais sensíveis**,

previsto no artigo 11 da LGPD. Dessa maneira, tanto o consentimento de que trata o artigo 14 guarda relação direta com o do artigo 11, inciso I, quanto as **bases legais do artigo 11, inciso II**, que autorizam o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do titular, podem **fundamentar o tratamento de dados de crianças e adolescentes**, respeitado o seu melhor interesse. Nas palavras dos autores, “Dados pessoais de crianças e adolescentes devem ser tratados de forma semelhante aos dados pessoais sensíveis, em uma categoria de dados especiais e com acréscimo da indispensável verificação de seu melhor interesse”⁷⁴.

Como sempre deve prevalecer o **melhor interesse da criança**, não será possível o tratamento de dados com fundamento no **legítimo interesse** do controlador ou de terceiro, pois o interesse que deve prevalecer é o da criança. Caso se adote a analogia com o tratamento de dados sensíveis, proposta por alguns estudiosos do tema, o legítimo interesse já não faz parte das bases legais que autorizam o tratamento desta categoria de dados.

Reitera-se que em toda operação de tratamento de dados de criança, além de se verificar a existência de base legal aplicável ao caso, deve se observar se o tratamento está em harmonia com o **melhor interesse da criança**.

⁷⁴ HENRIQUES, Isabela; PITA, Marina; HARTUNG, Pedro. **A Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes**. In DONEDA, Danilo [et al.]. **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 216.

Se isso não ocorrer, o tratamento será ilegal, ainda que realizado com o consentimento da mãe, do pai ou do responsável legal.

Importante que o controlador registre que na operação de tratamento levou em consideração o melhor interesse da criança, homenageando o princípio da **responsabilização**.

No que diz respeito ao **Tratamento de Dados de Adolescente**, a LGPD foi muito aberta, deixando mais dúvidas do que respostas, o que exigirá maior esforço interpretativo para se preservar os direitos do adolescente, pessoa humana em desenvolvimento. Como o destaque relativo ao consentimento não incluiu o adolescente, gerou **controvérsias** sobre o seu alcance.

Existem estudiosos da matéria que defendem a possibilidade de utilização de **qualquer base legal** para o tratamento de dados pessoais de adolescentes, bem como a **possibilidade de eles próprios consentirem**. Com relação ao uso de qualquer base legal para o tratamento de dados do adolescente, essa interpretação merece cautela, pois o tratamento dos dados do adolescente deve ser feito apenas em **seu melhor interesse**, o que limita, por exemplo, o uso do legítimo interesse do controlador, salvo se ele coincidir com o melhor interesse do adolescente. Quanto ao consentimento sem a interveniência da mãe, pai ou responsável legal, o tema gera **controvérsia** entre os estudiosos.

O Código Civil considera **absolutamente incapazes** de exercer atos da vida civil os menores de 16 anos (art. 3º do Código Civil), que devem ser **representados** judicial ou extrajudicialmente até os **16 anos** e **assistidos** até os **18 anos**, quando cessa a menoridade e a pessoa fica habilitada ao exercício de todos os atos da vida civil (art. 5º do Código Civil).

Tepedino e Oliva defendem que “[...] a autorização para o tratamento dos dados pessoais do adolescente, que deve ser dada por ele de forma livre, informada e esclarecida, não suplanta as regras previstas no Código Civil de celebração de negócios jurídicos, para cuja validade se mostra necessária a assistência ou a representação do adolescente, conforme o caso”⁷⁵.

Por outro lado, segundo Henriques, Pita e Hartung, “entende-se indispensável o consentimento parental ou de pessoa responsável legal para o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes até 16 anos de idade[...]”. Se o adolescente tiver entre 16 e 18 anos, os autores defendem que “será necessário o consentimento de ambos, não bastando o consentimento parental”⁷⁶.

⁷⁵ TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena. **Tratamento de dados de crianças e adolescentes na LGPD e o sistema de incapacidades do Código Civil** in LATERÇA, Priscilla Silva; FERNANDES, Elora; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; BRANCO, Sérgio (Coords.). **Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes**. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 313.

⁷⁶ HENRIQUES, Isabela; PITA, Marina; HARTUNG, Pedro. **A Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes**. In DONEDA, Danilo [et al.]. **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 213.

Diante desses diferentes cenários, o **melhor interesse do adolescente** será a baliza a fundamentar o tratamento dos seus dados pessoais. Permitir que o adolescente consinta irrestritamente, pode gerar severos prejuízos ao desenvolvimento da sua personalidade; por outro lado, simplesmente alijá-lo da vida digital não contribui para o seu desenvolvimento e interação em uma sociedade cada vez mais conectada. Trata-se de temática controvertida, que demandará contribuição apurada dos estudiosos do tema, diálogo das fontes e manifestação da ANPD, que proporcionará maior segurança jurídica às operações de tratamento de dados de adolescentes.

12.2 CASO XII – A ESCOLA INFANTIL XYZ E O USO DE IMAGENS DOS ESTUDANTES

A Escola de Educação Infantil XYZ trabalha com estudantes até o ensino fundamental I. A Escola costuma realizar diversas atividades com as crianças, postando vídeos e fotos em seu site e redes sociais. Para se resguardar sobre o uso da imagem das crianças, o contrato de prestação de serviços educacionais da Escola XYZ possui uma cláusula na qual as mães, pais ou responsáveis legais autorizam a captação e divulgação de imagens, sons e vídeos das crianças no site e nas redes sociais da escola, com a finalidade de promover as atividades educacionais realizadas. Caso os pais ou responsáveis não autorizem a divulgação das imagens, assinam outro modelo de contrato, que não possui essa cláusula.

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Agnelo, pai de Milene, de nove anos, estudante da Escola Infantil XYZ, questionou Silvina, diretora da Escola, sobre a postagem de um vídeo em uma rede social da escola, no qual Milene faz comentários sobre questões ambientais do município em que reside, como parte das atividades de uma disciplina.

Agnelo afirmou à diretora Silvina que nem ele e nem Ivone, sua esposa e mãe de Milene, autorizaram a divulgação do vídeo. A diretora respondeu que o contrato

Licenciado a: dssenna@gmail.com

de prestação educacional que Agnelo e Ivone assinaram na renovação da matrícula da filha para o presente ano letivo contém cláusula que autoriza a captação e divulgação de imagens, sons e vídeos da criança no ambiente escolar. Essa medida, reforçou a diretora, evita que a Escola solicite o consentimento ao longo do ano, diminuindo no dia a dia o incômodo às mães, aos pais ou responsáveis legais pela criança.

A diretora informou que o vídeo em questão foi gravado na sala de aula e a postagem servia para demonstrar o aprendizado do conteúdo e o desenvolvimento de competências, valorizando as crianças. Informou que não houve irregularidade, já que Agnelo e Ivone, ao assinarem o contrato de prestação de serviços educacionais com a Escola XYZ, consentiram com a divulgação de fotos e vídeos de Milene no site e nas redes sociais da Escola. De agora em diante, assinariam a versão do contrato que não autoriza a coleta de imagens e áudios, bloqueando postagens nas redes sociais da Escola com a imagem ou voz de Milene.

Insatisfeito com as explicações e buscando entender mais sobre o caso, Agnelo procurou-o, como profissional especializada(o) em proteção de dados, para orientá-los sobre as informações repassadas pela Escola Infantil XYZ.

Instruções: analise o caso à luz da LGPD, apontando eventuais pontos de conformidade e desconformidade com a Lei.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

12.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO XII

A LGPD cuida com especial atenção do tratamento de dados pessoais de crianças. Em primeiro lugar, exige que o tratamento seja realizado sempre no melhor interesse da criança ou do adolescente (art. 14). Quando o tratamento de dados for de criança, como no caso apresentado, exige o **consentimento específico e destacado** da mãe, do pai ou de um responsável legal (art. 14, §1º).

No caso em análise, Agnelo, pai de Milene, de nove anos, estudante do ensino fundamental na Escola XYZ, questionou a diretora sobre a publicação, nas redes sociais da escola, de um vídeo no qual Milene aparece discutindo questões ambientais do município, sem que a mãe ou o pai consentissem.

Silvina, diretora da Escola Infantil XYZ, respondeu que o contrato de prestação de serviços educacionais assinado por Agnelo e Ivone no início do ano contém cláusula que autoriza o tratamento de dados das crianças no ambiente escolar, restringindo a sua utilização a propósitos acadêmicos. Caso não concordassem com o tratamento dos dados de Milene para fins de divulgação de imagens, sons e vídeos em atividades escolares, poderiam assinar outro tipo de contrato, que não continha essa cláusula.

Como profissional de proteção de dados responsável pela análise do caso, informaria a Agnelo, salvo melhor
Licenciado a: dssenna@gmail.com

juízo, que o tratamento de dados de criança, como era o caso de sua filha Milene, não pode ser realizado com base em uma cláusula contratual geral, autorizando o tratamento de dados em situações genéricas. O tratamento de dados de criança, por força de disposição expressa na LGPD (art. 14, §1º), combinado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, exige que o consentimento seja **específico** e **destacado**, não podendo estar *camuflado* entre diversas cláusulas contratuais que tratam de temas diversos.

Dessa maneira, para cada atividade que demande a postagem de vídeo dos estudantes pela Escola XYZ, ela deveria coletar o consentimento específico e destacado de Agnelo ou Ivone, pai e mãe de Milene, sob pena de violação à LGPD. Embora a medida possa burocratizar algumas atividades escolares, contribuirá para a educação digital dos estudantes, professores e familiares das crianças, que entenderão melhor a importância dos seus dados pessoais e o consequente respeito que devem ter com os seus dados e os de terceiros, manifestações da própria personalidade humana.

Agnelo e Ivone podem autorizar determinado tipo de postagem, mas não outras. Como guardiães da autodeterminação informativa de Milene, devem zelar para que as pegadas digitais que estão sendo deixadas durante esse período importante de desenvolvimento da criança não tragam consequências negativas para o seu futuro. Aquilo que é postado em redes sociais dificilmente pode ser excluído, pois ainda que a pessoa se arrependa

Licenciado a: dssenna@gmail.com

e delete o arquivo, possivelmente ele já foi baixado ou replicado em outro lugar.

Em resumo, se a Escola XYZ souber antes do início do período letivo as atividades educacionais que demandarão a divulgação de imagens e sons das crianças, poderá coletar o consentimento específico e destacado da mãe, do pai ou responsável legal com antecedência. Mas se ainda não sabe as atividades que serão realizadas, a coleta de consentimento genérico, como foi feita no caso de Agnelo e Ivone, não atende às exigências da LGPD, que, como visto, tratou de maneira diferenciada a proteção dos dados da criança, preservando o seu melhor interesse para que possa desenvolver livremente a sua personalidade.

Por outro lado, exemplificativamente, a Escola XYZ pode tratar dados de Milene, mesmo sem o consentimento da mãe ou do pai, quando isso for necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, como é o caso do Censo da Educação.

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO XIII

HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA DA LGPD



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

13.1 HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA DA LGPD

A LGPD tem uma ampla esfera de aplicação e incidência. Incide sobre todas as pessoas jurídicas de **direito público e privado** que tratam dados pessoais ⁷⁷, além das **pessoas naturais** que tratam dados no exercício de atividade econômica. Existem situações, no entanto, que a LGPD expressamente **excluiu** de sua esfera de incidência. O **artigo 4º** da Lei, apresenta algumas hipóteses de tratamento de dados pessoais nas quais ela não se aplica.

Primeiramente, a LGPD **não se aplica** ao tratamento de dados “realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos”. Dessa maneira, o tratamento de dados realizado na esfera das **relações privadas das pessoas naturais** não está sujeito à incidência da LGPD. É o caso, por **exemplo**, da **agenda de celular** que contém dados de amigos, colegas e familiares, mas não são utilizados com **finalidade econômica**. Nessa hipótese, não há necessidade de adequação à LGPD.

⁷⁷ Em maior ou menor medida, todas as organizações tratam dados pessoais, ainda que sejam os dados dos próprios colaboradores.

Situação semelhante ocorre quando uma pessoa elabora uma lista com os dados pessoais de convidados para a sua festa de aniversário, com o objetivo de controlar o acesso ao condomínio no qual será realizada. Embora haja tratamento de dados, a LGPD não se aplica, pois o tratamento é realizado para fins particulares e não econômicos. Se a lista fosse deixada na portaria de um salão de festas por uma pessoa natural especializada em organização de festas, haveria o exercício de **atividade econômica**, atraindo a necessidade de adequação à LGPD.

A LGPD não incide sobre o tratamento de dados pessoais para **fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos**. Nesse caso, condicionar a atividade jornalística e artística à LGPD poderia restringir a liberdade de imprensa, de expressão e a livre manifestação do pensamento, pilares do Estado Constitucional e Democrático de Direito, com expressa previsão entre os princípios da Constituição Federal. A apuração jornalística e a consequente construção de matérias exigem o tratamento de dados pessoais, que poderá ser feito sem algumas restrições trazidas pela LGPD. Isso não significa que se tenha um “cheque em branco”, pois

⁷⁸ Ressalta-se que independentemente da incidência da LGPD, em toda situação que ocorre tratamento de dados é um dever de quem está tratando esses dados, ainda que excluído da aplicação da LGPD, como é o caso do particular que trata dados para atividades não econômicas, atentar para o que será feito com eles. À medida em que se constrói no Brasil uma cultura de privacidade e proteção de dados, bem como se avança com a educação digital, essas questões ficarão cada vez mais evidentes. Não é porque a LGPD não se aplica ao tratamento de dados para fins não econômicos, que esses dados podem ser deixados à própria sorte, sem assegurar a proteção e a segurança necessárias à sua preservação.

a **proteção de dados pessoais** também é um **direito fundamental**. Eventuais abusos podem – e devem – ser contidos e punidos com base em outras legislações.

Destaca-se que uma empresa jornalística não trata dados apenas para **finalidade jornalística**, excluída da incidência da Lei. As demais operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela empresa, como o tratamento dos dados dos seus colaboradores, assinantes e fornecedores, devem ser executadas em harmonia com a LGPD.

Situação semelhante ocorre com as **atividades artísticas**. **Por exemplo**: quando uma companhia de teatro trata dados pessoais para a caracterização de personagens na montagem de uma peça, está no exercício de sua atividade artística, razão pela qual a LGPD não se aplica. No entanto, nas operações de tratamento que realiza no âmbito empresarial, quando trata dados pessoais dos seus colaboradores, de espectadores das suas peças ou de fornecedores está sujeita à LGPD.

A LGPD também não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins **acadêmicos**, como pesquisas, elaboração de monografias, artigos científicos, dissertações, teses etc. Porém, sempre que possível, é necessário **anonimizar** os dados pessoais utilizados para atividade acadêmica. Parece razoável interpretar que quando a LGPD menciona que “**sempre que possível**” os dados devem ser anonimizados, a anonimização passa a ser a **regra**. Se não for possível anonimizar os dados

naquele caso concreto, importante **justificar** o motivo do impedimento.

O tratamento de dados pessoais realizado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais não está sujeito à LGPD, que recomendou a elaboração de lei específica “que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei” (art. 4, §1º, LGPD). Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei para tratar dessas situações, apelidado de **LGPD Penal**.

Nota-se em diversos pontos da aplicação de uma lei principiológica, como a LGPD, a **colisão entre direitos fundamentais**, que deve ser resolvida no caso concreto, balanceando os princípios colidentes, buscando uma aplicação equilibrada, que proporcione primazia ao princípio que tem maior peso para a elucidação do caso, mas reduzindo o máximo possível o impacto no princípio preterido, que pode ser o de maior peso em outra situação⁷⁹.

⁷⁹ Sobre normatividade dos princípios e colisão de direitos fundamentais, conferir: CANOTILHO, J. J. GOMES. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7ª ed. Lisboa, Portugal: Almedina, 2003, p. 1160 e ss; DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2010. ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Malheiros: São Paulo, 2008; FONSECA, Edson Pires da. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 67.

13.2 CASO XIII – A LGPD E A EMISSORA DE TELEVISÃO XYZ

A emissora de televisão XYZ nomeou um comitê interno para analisar a necessidade de adequação de suas operações à LGPD. Silvio, um dos integrantes do comitê, mencionou que embora fosse sempre importante o cuidado com os dados pessoais dos colaboradores e clientes da XYZ, não havia obrigatoriedade de adequação da emissora à LGPD, pois a Lei é expressa ao afirmar que não incide ao tratamento de dados realizado para fins exclusivamente “jornalístico e artísticos”.

Silvio defendeu que essa era uma importante vantagem para a emissora, pois evitava gastos elevados com programas de adequação à LGPD, além de excluí-la da esfera de incidência das pesadas sanções administrativas previstas na Lei, como as multas, que, pelo faturamento da XYZ, podem chegar a R\$ 50 milhões de reais por infração.

Em que pese tenha concluído pela desnecessidade de adequação à LGPD, por se tratar de uma empresa que tem no seu negócio principal a finalidade jornalística e artística, o comitê considerou pertinente a elaboração de um plano de resposta a incidentes, que são inevitáveis.

Depois desse levantamento inicial feito pelo comitê, a XYZ contratou a sua consultoria, especializada em proteção de dados pessoais, para analisar as conclusões

Licenciado a: dssenna@gmail.com

a que o comitê chegou, inclusive a de não incidência da LGPD às operações de tratamento da XYZ, já que não se aplica a tratamento para fins jornalístico e artísticos, que estão no centro das operações da emissora de televisão.

Instruções: analise o caso proposto, especialmente quanto às afirmações do comitê sobre a desnecessidade de adequação da Emissora XYZ à LGPD.

13.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO XIII

No caso em análise, o comitê criado pela emissora de televisão XYZ opinou pela desnecessidade de um programa de adequação à LGPD, já que a emissora tem no seu negócio principal a finalidade jornalística e artística, expressamente excluídas da esfera de incidência da Lei (art. 4º, II, “a”)⁸⁰.

Como consultoria contratada para analisar as conclusões do comitê, você deve esclarecer que, de fato, as atividades com finalidade jornalística e artística não estão sujeitas à incidência da LGPD, contudo, a emissora XYZ não trata dados pessoais apenas no exercício de atividades jornalística e artística. Trata dados de seus colaboradores, de parceiros comerciais, de anunciantes, entre outros.

Dessa maneira, embora no exercício das suas atividades fins, por expressa previsão legal, não haja

⁸⁰ Art. 4º **Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:** I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; **II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos;** ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei (sem grifos no original).

necessidade de adequação à LGPD, existem inúmeras outras operações de tratamento de dados realizadas pela emissora XYZ que necessitam de adequação à Lei.

Assim, fica evidente a necessidade de adequação da emissora XYZ à LGPD, mapeando os dados que estão sob seus cuidados, apontando a base legal que autoriza cada operação de tratamento, revendo seus contratos, sejam eles de trabalho ou com operadores de dados, para inclusão de cláusulas de privacidade e proteção de dados. Deve estabelecer uma robusta política de privacidade e proteção de dados, que servirá de norte para todos os colaboradores.

Programas de conscientização e treinamento devem ser implantados, pensando na educação permanente em proteção de dados de todos os colaboradores, fundamental para a implantação e manutenção de uma cultura de privacidade e proteção de dados na organização. Um aviso de privacidade, destinado ao público externo, dará o tom a todos os interessados de como o tratamento de dados será realizado na XYZ, homenageando o princípio da transparência. Programas de segurança da informação e de prevenção de incidentes, essenciais na adequação à LGPD, ajudarão no cumprimento dos princípios da segurança e da prevenção. A emissora XYZ já iniciou com bons passos, que foi a constituição do comitê e de uma consultoria para orientá-lo.

Percebe-se na proposta apresentada pelo comitê a necessidade de muito treinamento e acompanhamento,

Licenciado a: dssenna@gmail.com

o que pode ganhar sensível reforço com a nomeação do Encarregado de Proteção de Dados, que colocará a sua *expertise* em favor da construção da cultura de privacidade e proteção de dados da empresa. O plano de respostas a incidentes, já sugerido pelo comitê, é essencial, especialmente em uma emissora de televisão, que está bastante exposta e que seguramente será muito impactada por qualquer incidente, especialmente do ponto de vista reputacional.

Em resumo, embora as atividades com finalidade jornalística e artística estejam excluídas da necessidade de adequação à LGPD, isso não se aplica às demais operações de tratamento de dados executadas por empresas que atuam no segmento jornalístico e artístico, como é o caso da Emissora XYZ. Por isso, **necessita** de um robusto programa de adequação à LGPD. Apesar da atividade jornalística e artística estarem fora da incidência da LGPD, isso não significa que a empresa tem em mãos um “cheque em branco” para usar os dados como quiser, já que outras legislações podem incidir, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil, Código Penal, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, entre outras leis e atos normativos. Isso sem falar na própria **dignidade da pessoa humana**, um dos pilares da Constituição Federal de 1988. Desse modo, o trato cuidadoso dos dados pessoais é essencial no sistema jurídico adotado no Brasil, mesmo quando não há incidência direta da LGPD.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Edson Pires da Fonseca

ESTUDO DE CASO XIV

LEGÍTIMO INTERESSE DO CONTROLADOR



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

14.1 LEGÍTIMO INTERESSE DO CONTROLADOR

As **bases legais** são as **hipóteses** nas quais a LGPD **autoriza** o tratamento de dados pessoais. Se o tratamento não puder ser enquadrado em uma das bases legais do artigo 7º ou do artigo 11 (dados sensíveis), não pode ser realizado, pois carece de autorização legal.

O **consentimento** é a base legal mais conhecida e a que melhor homenageia a **autodeterminação informativa** do titular, porém não é a única e nem superior às demais. Um contraponto ao consentimento é o **legítimo interesse**, que permite o tratamento de dados, mesmo sem o consentimento do titular, quando houver um interesse legítimo do controlador ou de terceiro a esse respeito.

O legítimo interesse traz uma abertura para o tratamento de dados, buscando **equilibrar** a proteção dos dados pessoais do titular e o respeito à sua autodeterminação informativa com o desenvolvimento econômico, tecnológico e com a inovação, que seriam fortemente impactados se o consentimento do titular dos dados fosse absoluto.

Dessa maneira, inegável a abertura que a base legal legítimo interesse do controlador ou de terceiro

Licenciado a: dssenna@gmail.com

traz para o tratamento de dados pessoais, permitindo às organizações, obedecidos determinados parâmetros, a realização do tratamento mesmo sem o consentimento do titular, quando isso for necessário para atingir seus interesses legítimos.

Essa maior abertura proporcionada pelo legítimo interesse eleva o **risco jurídico** inerente à utilização desta base legal. Uma das maneiras de diminuir esse risco e trazer maior equilíbrio para a utilização dessa base legal é a prévia realização de uma **avaliação de legítimo interesse**⁸¹, que documentará o raciocínio realizado pelo controlador para demonstrar que o tratamento daqueles dados pessoais é necessário para que os seus interesses legítimos sejam atingidos, bem como certificar a existência de **proporcionalidade** entre o tratamento e as expectativas do titular dos dados e a ausência de violação aos seus direitos e liberdades fundamentais⁸².

Um **filtro** importante na utilização do legítimo interesse é a **legítima expectativa do titular** de que seus dados serão tratados. A legítima expectativa deve ser considerada em toda operação de tratamento que se valha do legítimo interesse, “ainda que ela não venha a prevalecer no resultado final do balanceamento de interesses em jogo, por não ser um valor absoluto (e.g.,

⁸¹ Em inglês, a avaliação de legítimo interesse é denominada LIA, “Legitimate Interest Assessment”.

⁸² Artigo 7º, IX – “quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”.

prevenção a fraudes)”⁸³.

O **artigo 10 da LGPD** apresenta um rol exemplificativo de situações concretas nas quais o legítimo interesse pode fundamentar o tratamento de dados pessoais:

Art. 10. O **legítimo interesse** do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para **finalidades legítimas**, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

I - apoio e promoção de **atividades** do controlador;
e

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as **legítimas expectativas** dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais **estritamente necessários** para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a **transparência** do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá **solicitar** ao controlador **relatório de impacto** à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial (sem grifos no original).

⁸³ BIONI, Bruno; KITAYAMA, Marina; RIELLI, Mariana. O Legítimo Interesse na LGPD: quadro geral e exemplos de aplicação. São Paulo: Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, 2021, p. 7.

O legítimo interesse do controlador ou de terceiro será uma das bases legais mais utilizadas no cotidiano das organizações. Porém, para que o seu uso não eleve os riscos jurídicos inerentes à sua utilização para níveis desproporcionais, o controlador deve se cercar de todos os cuidados necessários, adotando **medidas e salvaguardas** para redução dos riscos aos direitos dos titulares.

Além da avaliação de legítimo interesse, se houver riscos aos direitos e liberdades fundamentais do titular o controlador deve elaborar o **RIPD, relatório de impacto à proteção de dados**, no qual analisará os riscos, as salvaguardas e as medidas mitigadoras que podem reduzi-los. Se não for possível reduzir os riscos aos direitos e às liberdades dos titulares dos dados a níveis aceitáveis e proporcionais aos benefícios que o controlador terá não será possível realizar o tratamento daqueles dados.

Por conta de sua maior abertura e risco, parece **prudente** utilizar a base legal do legítimo interesse apenas quando o tratamento não puder, com segurança, ser enquadrado em outra base legal. Na ausência de outra base legal aplicável, o controlador deve analisar a adequação do caso aos requisitos necessários à utilização do legítimo interesse, documentando o processo de seleção da referida base legal como a adequada ao caso, homenageando o **princípio da responsabilização**.

A maneira mais propagada de avaliar a adequação do legítimo interesse ao caso concreto é a utilização da

Avaliação de Legítimo Interesse, mais conhecida pela sigla em inglês **LIA**, *Legitimate Interest Assessment*.

Palhares, Prado e Vidigal, no entanto, entendem que a realização da LIA é uma excelente forma de atender o princípio da responsabilização, mas não é a única. O receio dos autores é que a realização da LIA em todas as operações que utilizam o legítimo interesse onere e burocratize excessivamente o *compliance* de privacidade e proteção de dados. Nas palavras dos autores:

Temos de lembrar que recursos financeiros e humanos para o tema são finitos, razão pela qual um programa de privacidade, em qualquer organização, sempre vai exigir delimitações de escopo e prioridades. A nosso ver, LIA para casos banais e triviais de legítimo interesse jamais deveria estar nessa camada prioritária, razão pela qual entendemos que a utilidade e aplicação do LIA (ou metodologia de avaliação de aplicabilidade do legítimo interesse) deveria se resumir a situações práticas cuja complexidade de definição da base legal realmente assim exija⁸⁴.

Em situações mais simples, o registro do processo decisório seria suficiente para justificar a utilização da base legal. Para os autores, o legítimo interesse não é a base legal de aplicação mais aberta da LGPD, destacando a proteção ao crédito e a prevenção à fraude e garantia

⁸⁴ PALHARES, Felipe; PRADO, Luís Fernando; VIDIGAL, Paulo.

Compliance Digital e LGPD. Coleção Compliance, V. 5. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 188.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

de segurança. Palhares, Prado e Vidigal⁸⁵ sustentam que se houver questionamento sobre a utilização do legítimo interesse, existem outras formas de demonstrar que a organização foi diligente na escolha da base legal, como atas de reuniões, trocas de e-mails, consultas a especialistas etc.

Analisando a problemática por esses diferentes ângulos, parece-nos necessário o registro do processo decisório que culminou no enquadramento do tratamento de dados à base legal do legítimo interesse. Ainda que de maneira mais ou menos simplificada, a utilização do legítimo interesse é precedida de algum tipo de avaliação. Contudo, nem sempre a utilização do legítimo interesse gera dúvida sobre a sua adequação ou riscos elevados aos direitos e liberdades dos titulares. Em situações como essa, um registro mais simplificado do processo decisório pode atender ao princípio da responsabilização.

Ainda que seja um processo de documentação simplificado, documentar adequadamente a utilização do legítimo interesse demonstrará respeito ao princípio da responsabilização, dará mais transparência ao processo decisório, mas sem burocratizá-lo excessivamente.

Destaca-se que a **impossibilidade** de enquadramento do tratamento de dados em outra base legal não é razão suficiente para autorizar o uso do legítimo interes-

⁸⁵ PALHARES, Felipe; PRADO, Luis Fernando; VIDIGAL, Paulo. **Compliance Digital e LGPD**. Coleção Compliance, V. 5. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 188.

se, o que somente poderá ocorrer se o tratamento cumprir integralmente os requisitos para a utilização desta base legal.

Embora a ANPD ainda não tenha regulamentado as **hipóteses de prévia elaboração obrigatória do RIPD**, não parece razoável que toda a utilização do legítimo interesse seja precedida da elaboração do RIPD, o que oneraria, sobremaneira, o controlador. O RIPD deve ser elaborado quando houver **risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais** dos titulares dos dados⁸⁶. No caso de **dúvida** sobre a elaboração ou não do relatório, **recomenda-se que seja elaborado**, o que homenageia, inclusive, o princípio da **prevenção**.

⁸⁶ De acordo com o artigo 5º, XVII, da LGPD, o “relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais **que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais**, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco”. Dessa maneira, há atividades de tratamento que podem ser fundamentadas no legítimo interesse, mas que não representam riscos significativos às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular, como seria o caso do envio de um e-mail *marketing* para um cliente que adquiriu um produto em um *e-commerce*.

14.2 CASO XIV – SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO

A Empresa XYZ decidiu instalar câmeras de vigilância em todas as suas dependências, proporcionando maior segurança aos colaboradores e ao patrimônio da empresa, especialmente depois que sofreu um furto sem elucidação. Como passou a tocar um projeto sigiloso, o monitoramento buscava ampliar a segurança. Destacase que os espaços monitorados eram apenas os de uso comum; não foram instaladas câmeras em espaços de uso privativo e nem nos ambientes destinados ao descanso dos funcionários, entrada dos banheiros e do refeitório. As estações de trabalho, por sua vez, estavam instaladas em ambientes compartilhados e monitorados.

O funcionamento do sistema de monitoramento foi precedido de intensa divulgação pelo RH da XYZ, que informou como as câmeras funcionariam, os locais em que estavam instaladas, o que elas captavam e os motivos que levaram a empresa a instalá-las. Todo esse processo estava documentado na política de privacidade da empresa.

Josias, colaborador da XYZ, depois de ver as câmeras instaladas e os avisos de que o ambiente estava sendo monitorado, informou ao RH que não consentiu para o registro de sua imagem. Afirmou entender os riscos de segurança relatados pela empresa, mas que isso não justificava tornar o ambiente um verdadeiro “big brother”,

Licenciado a: dssenna@gmail.com

em detrimento da privacidade dos colaboradores da XYZ.

Lucinda, supervisora do RH, informou a Josias que o projeto de monitoramento estava em sintonia com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que o assunto passou por intenso debate no comitê interno de proteção de dados pessoais. Josias foi informado que a empresa elaborou um relatório para analisar eventuais impactos que o monitoramento traria aos direitos dos colaboradores e demais visitantes que transitassem pelo ambiente. Todo monitoramento foi registrado e inserido na política de privacidade da XYZ.

Josias, no entanto, respondeu que não havia sentido dizer que o monitoramento estava em conformidade com a LGPD, se ele e outros colegas com os quais conversou não consentiram com o monitoramento e ele sabia que para a empresa tratar seus dados isso era indispensável.

Para dirimir de vez as dúvidas de Josias, Lucinda, supervisora do RH, pediu a você, destacada(o) profissional de proteção de dados pessoais e DPO da XYZ, que explique às colaboradoras e aos colaboradores o motivo de não ter sido coletado o consentimento deles para o monitoramento e se a LGPD autorizava essa medida.

Instruções: analise o caso e explique os pontos abordados por Lucinda.

14.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO XIV

No caso em análise, Josias, funcionário da Empresa XYZ, questionou a instalação de câmeras de vigilância em áreas de acesso comum da empresa, especialmente porque não foi solicitado o consentimento dele e dos demais colegas.

Como encarregada(o) de dados da XYZ, esclareça Josias e os demais colaboradores que em algumas situações a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sem a necessidade do consentimento do titular dos dados. Faz isso, por exemplo, quando necessita tratar dados para o exercício regular de direito em eventual processo judicial (trata dados relativos à jornada de trabalho do colaborador para provar que não excedeu as horas remuneradas), quando necessita cumprir uma obrigação legal, como o repasse de informações dos funcionários ao e-Social, entre outras hipóteses.

Quanto à **instalação das câmeras de monitoramento**, a base legal que autoriza o tratamento dos dados é o **legítimo interesse** do controlador, no caso, a Empresa XYZ. A empresa tomou medidas necessárias para **balancear** o direito dos titulares dos dados com os seus interesses legítimos, restringindo a coleta de imagem a ambientes comuns, não coletando sons e preservando integralmente a privacidade nas áreas que não são destinadas ao trabalho. A medida torna mais

Licenciado a: dssenna@gmail.com

seguro o ambiente de trabalho, que já foi alvo de atividade suspeita. Os dados coletados, reitera-se, são apenas os mínimos necessários para que se atinja a finalidade do tratamento.

A escolha da base legal que fundamenta o tratamento de dados é de responsabilidade do controlador, que deve escolher entre as dez hipóteses previstas no artigo 7º da LGPD a que melhor se amolda ao caso. Se os dados tratados forem sensíveis, as hipóteses de tratamento estão previstas no artigo 11 da LGPD.

Importante esclarecer aos colaboradores que o consentimento não foi solicitado porque **não é a base legal adequada** para o tratamento de dados realizado pela XYZ. Para que o consentimento seja válido, precisa ser livre, porém como as relações de trabalho são de **subordinação**, faltaria ao consentimento o cumprimento de requisitos básicos, tornando esta base legal inadequada para fundamentar o tratamento de dados em análise. Difícil demonstrar que o consentimento foi livre quando a relação é de subordinação, invalidando o seu uso no caso concreto.

Dessa maneira, o consentimento não foi utilizado por não ser a base legal adequada ao caso. No entanto, a Empresa XYZ tomou as medidas necessárias para que o tratamento de dados fosse realizado em conformidade com a LGPD, dando ampla publicidade ao monitoramento por câmeras, homenageando o princípio da **transparência**,

Licenciado a: dssenna@gmail.com

que deve nortear as relações entre controladores e titulares dos dados pessoais. Também minimizou os dados coletados, além de adotar salvaguardas para mitigação de riscos no uso do legítimo interesse, elaborando avaliação de legítimo interesse (LIA) e relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD).

Embora a LGPD não exija expressamente que o uso do legítimo interesse seja precedido de avaliação de legítimo interesse, a XYZ optou por realizá-la. Em que pese o comitê de proteção de dados tenha entendido que não seria obrigatório para o caso, elaboraram um relatório de impacto à proteção de dados pessoais no qual as medidas de segurança e as salvaguardas adotadas para mitigar riscos aos direitos e às liberdades fundamentais dos titulares dos dados foram documentados.

Em resumo, o tratamento de dados realizado pela Empresa XYZ está em conformidade com a LGPD, que elenca nove hipóteses, além do consentimento, nas quais o tratamento de dados pessoais é autorizado. No caso em tela, a base legal utilizada foi o legítimo interesse do controlador, sendo adotadas as medidas necessárias para a utilização desta base legal, que por sua abertura e subjetividade, aumenta o dever de fundamentação do controlador. Ressalta-se que manifestações futuras da ANPD podem alterar o entendimento sobre a realização da avaliação de legítimo interesse e do relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

ESTUDO DE CASO XV

RESPONSABILIDADE E RESSARCIMENTO



Licenciado a: dssenna@gmail.com

LGPD



Casos

15.1 RESPONSABILIDADE E RESSARCIMENTO

A responsabilidade e o ressarcimento dos danos são tratados nos artigos 42 a 45 da LGPD. A Lei estabelece que o controlador ou o operador que ao tratar dados pessoais causar dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo.

O **responsável** pelo tratamento e, portanto, quem tem o dever de reparar eventual dano é o **controlador**, que é o grande protagonista das operações de tratamento de dados. O **operador**, no entanto, responde **solidariamente** com o controlador em duas situações:

- (i) **quando descumprir ordem lícita do controlador;**
- (ii) **quando violar a LGPD.**

Excetuadas as hipóteses acima, a responsabilidade pelo incidente será do controlador. Isso não tira do operador o **dever de zelar** pelos dados que estão sob sua responsabilidade, até porque, se não o fizer, descumprirá a LGPD e atrairá para si a responsabilidade. De acordo com a LGPD, quando o operador descumpre as ordens lícitas

do controlador ou a Lei ele se **equipara ao controlador**, ficando responsável pelos danos causados.

Destaca-se que o **contrato** entre o controlador e o operador estabelecendo parâmetros e limites para a execução do tratamento de dados será importante para se aferir, no caso concreto, se o operador descumprir ordens lícitas do controlador, que estarão estabelecidas contratualmente. A própria ANPD considerou que essa é uma **boa prática**, embora não esteja expressa na LGPD.

53. O conceito e o escopo de atuação do operador indicam, também, a importância das definições contratuais para a relação entre controlador e operador. **Ainda que a LGPD não determine expressamente que o controlador e o operador devam firmar um contrato sobre o tratamento de dados, tal ajuste se mostra como uma boa prática** de tratamento de dados, uma vez que as cláusulas contratuais impõem limites à atuação do operador, fixam parâmetros objetivos para a alocação de responsabilidades entre as partes e reduzem os riscos e as incertezas decorrentes da operação (sem grifos no original) ⁸⁷.

⁸⁷ Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 16.

A LGPD estabelece que no caso de **controladoria conjunta**⁸⁸, ou seja, quando houver mais de um controlador diretamente envolvido no tratamento do qual decorra danos aos titulares, responderão **solidariamente** pelos danos⁸⁹. No entanto, quem indenizou os danos tem o **direito de regresso** em relação aos demais responsáveis

Outro ponto que a Lei destaca, bastante comum no direito do consumidor e ampliado pelo atual Código de Processo Civil, é a possibilidade de **inversão do ônus da prova** a favor do titular dos dados, quando o juiz, no processo civil, considerar a alegação **verossímil**, houver **hipossuficiência** ou **onerosidade excessiva** na produção da prova⁹¹. O ônus de provar uma alegação, em regra, é de quem a fez, mas em situações como a descrita na LGPD, de verossimilhança, hipossuficiência ou onerosidade

⁸⁸ Embora a LGPD não utilize expressamente a expressão **controladoria conjunta**, a ANPD esclarece que “embora a LGPD não explicita o conceito de controladoria conjunta, é possível inferir que ele está contemplado no sistema jurídico de proteção de dados”. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado**. Brasília, DF: ANPD, 2021, p. 12.

⁸⁹ Art. 43, §1º, II: “os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei”.

⁹⁰ Art. 43, § 4º: “Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso”.

⁹¹ Art. 42, § 2º: “O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa”.

excessiva, o ônus da prova pode ser invertido, passando para os agentes de tratamento.

A Lei estabelece que as ações de reparação por **danos coletivos** provocados pelos agentes de tratamento podem ser exercidas coletivamente em juízo⁹².

De acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais será irregular quando desobedecer a Lei ou não fornecer ao titular a segurança que dele pode se esperar. Quem ainda **não se adequou à LGPD**, está tratando dados pessoais irregularmente desde 18 de setembro de 2020 e, portanto, sujeito às sanções administrativas ou judiciais decorrentes da violação à Lei.

O cuidado com a segurança deve ser pensado desde a concepção do produto ou serviço (**Privacy by Design**), prevenindo a ocorrência de incidentes, que são de difícil – e muitas vezes impossível – reversão. Embora a LGPD não conceitue, considera-se **incidente** a violação da **confidencialidade**, **integridade** e **disponibilidade**, considerados o **tripé** da segurança da informação.

A LGPD destaca algumas **circunstâncias** que considera **relevantes**:

- (i) o modo como o tratamento de dados é realizado;

⁹² Art. 42, § 3º “As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente”.

- (ii) o resultado e os riscos esperados;
- (iii) técnicas e tratamentos disponíveis à época.

Espera-se que o tratamento seja realizado adotando as melhores técnicas e boas práticas disponíveis, dentro de um contexto de **razoabilidade**. Não é razoável exigir que uma microempresa tenha equipamentos de segurança da informação tão sofisticados quanto uma *big tech*, o que não a isenta de empregar os **melhores recursos** disponíveis dentro das suas **circunstâncias**. Por esse motivo, a ANPD está tratando diferenciadamente os chamados **agentes de tratamento de pequeno porte**, adaptando as exigências da Lei à realidade desses agentes.

Se a organização não for capaz de proporcionar um **tratamento de dados seguro** aos titulares, não deverá realizá-lo. Tratamento seguro não quer dizer imune a risco, mas que os **riscos** tenham sido objeto de análise detalhada e que tenham sido adotadas as **salvaguardas** necessárias para a sua mitigação.

O agente de tratamento que deixar de adotar as **medidas de segurança** previstas no artigo 46 da LGPD⁹³

⁹³ **Art. 46.** “Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. §1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei. § 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução”.

responde pelos danos decorrentes da violação de segurança (art. 44, par. único).

No artigo 43, a LGPD apresenta algumas hipóteses de **exclusão de responsabilidade**. Os agentes de tratamento não serão responsabilizados quando provarem:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

Se o agente não realizou o tratamento, obviamente não pode ser responsabilizado, pois inexiste **nexo** entre a sua atuação e o dano. Acontece que, na prática, nem sempre é fácil demonstrar quem realizou o tratamento, o que fez com que o legislador optasse pela “responsabilidade solidária dos agentes envolvidos”⁹⁴.

⁹⁴ BRUNO, Marcos Gomes da Silva. **Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais**. In MALDONADO, Viviane; OPICE BLUM, Renato (Coords). LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 328.

Outra hipótese de **exclusão de responsabilidade** ocorre quando o tratamento que resultou no incidente foi realizado em conformidade com a LGPD. Um dos princípios da LGPD é o da segurança, normalmente violado quando ocorre um incidente. Deve-se verificar, no caso concreto, se o padrão de segurança adotado atende aos requisitos previstos na Lei.

Por último, os agentes de tratamento não serão responsabilizados se o dano provocado pelo tratamento de dados for decorrente de **culpa exclusiva** do titular dos dados ou de terceiros.

Quanto à **natureza da responsabilidade na LGPD**, se objetiva ou subjetiva, há **divergências** entre os estudiosos da matéria. A responsabilidade objetiva assegura maior proteção aos dados pessoais, atendendo a teleologia e a sistematicidade da Lei, bem como o caráter de direito fundamental que reveste a proteção de dados.

Do ponto de vista da literalidade do texto normativo, a interpretação que parece estar mais em conformidade com o disposto na Lei é a que considera a coexistência da responsabilidade subjetiva e objetiva. Pelas razões apresentadas, a questão da natureza jurídica da responsabilidade civil na LGPD demandará análise mais detida do Poder Judiciário e da ANPD. Para melhor compreensão do tema, indicamos, dentre outras, as obras

Licenciado a: dssenna@gmail.com

que estão nesta nota de rodapé⁹⁵.

⁹⁵ Marcos Bruno destaca que nos incidentes com dados que causem danos a consumidores, a responsabilidade será objetiva; nos demais casos, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. BRUNO, Marcos Gomes da Silva. **Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais**. In MALDONADO, Viviane; OPICE BLUM, Renato (Coords). LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 325; Anderson Schreiber, destaca que “Em suma, apesar da redação algo confusa, pode-se concluir que convivem na LGPD dois regimes distintos de responsabilidade civil: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. É, de resto, o que ocorre no Código Civil, no qual convivem as cláusulas gerais de responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c art. 927, *caput*) e objetiva (art. 927, parágrafo único), bem como no Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva nos arts. 12, *caput*, e 14, *caput*, por exemplo; e responsabilidade subjetiva no art. 14, §4º), sendo certo que esses dois diplomas legislativos parecem ter guiado, acertadamente, as opções do legislador especial na disciplina do tratamento de dados pessoais”. SCHREIBER, Anderson. **Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**. In DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pp. 328 e 329. A Professora Caitlin Mulholland, defende que o regime adotado foi a da responsabilidade civil objetiva: “Conclui-se, portanto, que apesar do uso de expressões diversas em sua redação, tanto o artigo 42, quanto o artigo 44, da LGPD, adotam o fundamento da responsabilidade civil objetiva, impondo aos agentes de tratamento a obrigação de indenizar os danos causados aos titulares de dados, afastando destes o dever de comprovar a existência de conduta culposa por parte do controlador ou operador. Fundamenta esta conclusão o fato de que a atividade desenvolvida pelo agente de tratamento é evidentemente uma atividade que impõe riscos aos direitos dos titulares de dados, que, por sua vez, são intrínsecos, inerentes à própria atividade e resultam em danos a direito fundamental. Ademais, tais danos se caracterizam por serem quantitativamente elevados e qualitativamente graves, ao atingirem direitos difusos, o que, por si só, já justificaria a adoção da responsabilidade civil objetiva, tal como no caso dos danos ambientais e dos danos causados por acidentes de consumo”. MULHOLLAND, Caitlin. **A LGPD e o fundamento da responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados pessoais: culpa ou risco?** Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/329909/a-lgpd-e-o-fundamento-da-responsabilidade-civil-dos-agentes-de-tratamento-de-dados-pessoais--culpa-ou-risco>, acessado em 20.10.2021.

15.2 CASO XV – O CONCERTO DO NOTEBOOK DA CLÍNICA BETA

A WYF Informática prestava serviços para a Clínica de Psicologia Beta. Com a promulgação da LGPD, incluíram no contrato de prestação de serviços um adendo sobre proteção de dados pessoais, no qual a WYF Informática se comprometia a operar em conformidade com a Lei, bem como uma série de cuidados com os dados de clientes da Clínica Beta, muitos deles dados pessoais sensíveis, dentre os quais a confidencialidade e a vedação total a qualquer tipo de compartilhamento.

Certa ocasião, o notebook utilizado por uma psicóloga da Clínica Beta *travou*, sendo, então, encaminhado à WYF Informática para manutenção. O *HD* do notebook continha dados de pacientes da Clínica. Depois de cerca de quatro semanas da manutenção do notebook, Germano, paciente da Beta, procurou a Clínica informando que estava sendo chantageado por uma pessoa que teve acesso ao seu prontuário e ameaçava divulgar na *internet* caso ele não pagasse, em criptomoedas, a quantia estipulada pelo criminoso.

Após apuração interna, a Clínica Beta detectou que os dados de Germano estavam no notebook enviado à WYF para manutenção. Em seguida, detectaram que outros pacientes, cujos dados estavam no mesmo notebook, também foram chantageados por alguém que teve acesso aos seus prontuários.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

Informada do problema, a WYF instaurou um procedimento interno de investigação e detectou que um colaborador que trabalhou na manutenção do notebook havia subtraído os dados e compartilhado com um amigo, que estava chantageando as vítimas.

A Clínica Beta e a WYF Informática decidiram não comunicar a ANPD e nem os titulares dos dados sobre o incidente, enquanto tentavam, com a ajuda do agora ex-colaborador, que foi demitido após a descoberta do incidente, recuperar os dados que estavam em posse do criminoso.

Germano, o primeiro paciente que foi vítima de chantagem, procurou um escritório de advocacia para defender os seus direitos. O advogado foi informado pela Clínica Beta que o vazamento ocorreu na WYF Informática, que era a única responsável pelo incidente. O advogado, no entanto, informou ao seu cliente que a Clínica Beta era a única responsável, pois na LGPD apenas o controlador responde pelos danos causados por eventual incidente. A WYF Informática, embora possuísse maior capacidade financeira, não poderia responder pelos danos provocados pelo incidente, porque era apenas a operadora, que tratava os dados em nome da sua cliente, a Clínica Beta, seguindo as suas ordens lícitas.

INSTRUÇÕES: Interessado em uma segunda opinião, Germano procurou o seu escritório, especializado em proteção de dados, para orientá-lo.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

15.3 DA TEORIA À PRÁTICA: RESOLUÇÃO DO CASO XV

No caso em análise, a Clínica Beta era a controladora dos dados dos seus pacientes, enquanto a WYF Informática era a operadora, ou seja, tratava eventualmente dados de pacientes e colaboradores da Clínica Beta, seguindo as suas ordens lícitas e a LGPD.

A Clínica Beta poderia ter tomado medidas de prevenção e segurança mais eficientes para a proteção dos dados que estavam sob sua responsabilidade, muitos deles dados sensíveis, com elevada capacidade de dano aos direitos dos titulares em caso de incidente. A relação entre psicóloga(o) e paciente é pautada na confidencialidade e no sigilo profissional, razão pela qual as medidas de proteção adotadas devem proporcionar segurança aos dados daquele que confiou seus segredos mais íntimos e agora é chantageado. Se os dados estivessem **pseudonimizados**, salvos em nuvem e o notebook criptografado o acesso a eles seria mais difícil em uma situação como a narrada no caso, na qual o notebook precisou ser levado repentinamente para manutenção.

De outro lado, a WYF Informática também falhou ao não proporcionar a segurança esperada pelos seus clientes na realização da prestação de serviços⁹⁶. A

⁹⁶ Art. 44. O tratamento de dados pessoais será **irregular** quando **deixar de observar a legislação** ou **quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar**, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

Licenciado a: dssenna@gmail.com

conformidade com a LGPD exige que a WYF adote medidas de prevenção que evitem que incidentes como este ocorram, em especial, por saber, inclusive por disposição contratual expressa, da sensibilidade dos dados tratados pela Clínica Beta.

O advogado de Germano está certo ao afirmar que a responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais é do controlador. Equivoca-se, no entanto, ao tratá-la como absoluta. O operador atrai para si a responsabilidade por eventuais danos provocados pelo tratamento de dados em duas hipóteses: (i) quando desobedece a ordens lícitas do controlador; (ii) quando viola a LGPD. No caso em análise, tivemos violação da LGPD, pois medidas de segurança e prevenção que poderiam ter evitado o incidente não foram adotadas, violando os princípios da segurança e da prevenção, previstos no artigo 6º, incisos VII e VIII. O artigo 44 da LGPD também é expresso ao considerar irregular o tratamento de dados quando deixar de observar a legislação ou não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. Ao violar a LGPD, o operador passa a se responsabilizar pelos danos oriundos do incidente⁹⁷. A

⁹⁷ Art. 42. O **controlador ou o operador** que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem **dano patrimonial, moral, individual ou coletivo**, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o **operador responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador **equipara-se ao controlador**, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei (sem grifos no original).

responsabilidade será solidária entre a Clínica Beta e a WYF Informática.

Quanto à **comunicação do incidente**, a Clínica Beta, como controladora dos dados, tinha o dever de comunicar à ANPD e aos titulares dos dados sobre o incidente, o que deveria ter sido feito em, no máximo, **dois dias úteis** depois da descoberta do incidente. O ideal seria avisar em prazo inferior, imediatamente após a constatação do incidente, ainda que posteriormente fosse necessário complementar as informações. Embora a obrigação seja do controlador, a ANPD receberá comunicação de incidente feita pelo operador⁹⁸.

⁹⁸ Conferir o Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado, publicado pela ANPD em maio de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf, acessado em 19 de outubro de 2021.

REFERÊNCIAS

BIONI, Bruno; KITAYAMA, Marina; RIELLI, Mariana. **O Legítimo Interesse na LGPD: quadro geral e exemplos de aplicação.** São Paulo: Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, 2021.

BRUNO, Marcos Gomes da Silva. **Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais.** In MALDONADO, Viviane; OPICE BLUM, Renato (Coords). **LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 328.

DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (Coords.). **LGPD & Administração Pública: uma análise ampla dos impactos.** Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 2020.

DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais.** Rio de Janeiro: Forense, 2021.

FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; CALAZA, Tales (Coords.). **Legal Design: Teoria e Prática.** Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

FONSECA, Edson Pires da. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**. Salvador: Juspodivm, 2021.

LATERÇA, Priscilla Silva; FERNANDES, Elora; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; BRANCO, Sérgio (Coords.). **Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes**. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book.

OPICE BLUM, Renato (Org.). **Proteção de Dados: desafios e soluções na adequação à Lei**. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

PALHARES, Felipe; PRADO, Luis Fernando; VIDIGAL, Paulo. **Compliance Digital e LGPD**. Coleção Compliance, V. 5. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

PRUDENTE DO AMARAL, Luiz Fernando de Camargo. **Desafios da LGPD em Relação à Implementação pelo Poder Público**. In OPICE BLUM, Renato (Org.). **Proteção de Dados: desafios e soluções na adequação à Lei**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 77 a p. 92.

SCHREIBER, Anderson. **Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**. In DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pp. 319 a 338.

SOUZA, Bernardo de Azevedo; OLIVEIRA, Ingrid Barbosa (Orgs). **Visual Law**: como elementos visuais podem transformar o direito. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

TASSO, Fernando. **A Lei Geral de Proteção de Dados e os Tribunais – Desafios para Implementação**. In OPICE BLUM, Renato (Org.). **Proteção de Dados: desafios e soluções na adequação à Lei**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 63 a p. 76.

TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena. **Tratamento de dados de crianças e adolescentes na LGPD e o sistema de incapacidades do Código Civil** in LATERÇA, Priscilla Silva; FERNANDES, Elora; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; BRANCO, Sérgio (Coords.). **Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes**. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 313.

WIMMER, Miriam. **O Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**. in DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo; MENDES, Laura S.; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). BIONI, Bruno (Coord. Executivo). **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 280.

Edson Pires da Fonseca



ISBN: 978-65-00-28788-2

td



9 786500 287882

Licenciado a: dssenna@gmail.com